OBJECTIF BARREAU

# LES ESSENTIELS DU DROIT

-

# Les grands principes de la justice civile

**Thème I – Les grands principes régissant l'organisation de la justice française .....5**

**Partie I : La consécration d'une dualité des ordres juridictionnels .....5**

Titre I : L'émergence d'un ordre juridictionnel administratif .....5

Titre II : La répartition des compétence entre les deux ordres juridictionnels .....7

Titre III : Les garanties statutaires de l'exercice des pouvoirs juridictionnels .....40

**Partie II : La hiérarchisation des juridictions au sein de chaque ordre juridictionnel .....46**

Titre I – L'organisation pyramidale des juridictions ordinaires .....46

Titre II – Le rôle fondamental de certaines juridictions hors hiérarchie .....47

**Thème II – Les grands principes régissant le fonctionnement de la justice française .....56**

**Partie I – Les principes fondamentaux relatifs à l'exercice d'une action en justice .....56**

Titre I – Le principe d'égalité devant la justice .....56

Titre II – Le principe de gratuité de la justice .....57

Titre III – Le principe de continuité du service public de la justice.....61

**Partie II – Les principes fondamentaux relatifs au déroulement de l'instance .....62**

Titre I – Le droit à la publicité de la justice.....62

Titre II – Le droit à la célérité de la justice .....63

**Partie III - La responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice .....64**

Titre I – Le dysfonctionnement de la justice judiciaire.....64

Titre II – Le dysfonctionnement de la justice administrative .....65

La conception française de la justice présente des spécificités qu'il est indispensable de maîtriser, car elles conditionnent l'acquisition d'une vision d'ensemble de ce qu'est le service public de la justice. Il faut ainsi connaître les grands principes régissant l'organisation (THEME I) et le fonctionnement (THEME II) de la justice française.

# THEME I – LES GRANDS PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION DE LA JUSTICE FRANÇAISE

La justice française se caractérise par la répartition des juridictions en deux grands ordres juridictionnels : c'est le principe de « dualité des juridictions » (PARTIE I). Au sein de chacun de ces ordres, il existe une hiérarchie entre les différentes juridictions (PARTIE II).

## PARTIE I : LA CONSECRATION D'UNE DUALITE DES ORDRES JURIDICTIONNELS

De façon très schématique, le pouvoir de dire le droit est réparti entre les juridictions chargées de connaître des litiges entre personnes privées, dites juridictions de l'ordre « judiciaire », et celles chargées de connaître des litiges entre l'Etat et les personnes privées, qui sont les juridictions de l'ordre « administratif ».

Cette dualité juridictionnelle est éminemment tributaire de la conception de la séparation des pouvoirs, et donc d'une certaine conception politique de l'organisation de l'Etat. C'est ce qui explique que, si les juridictions judiciaires ont pu évoluer dans leur diversité et leur composition, le principe même de leur existence n'a guère posé de difficultés, contrairement aux juridictions administratives dont la création a été le fruit d'une lente évolution (TITRE I). Une fois la dualité juridictionnelle mise en place, il a fallu répartir les matières juridiques entre chaque ordre de juridiction, et trouver des méthodes pour résoudre les conflits de compétence qu'une telle répartition engendre inévitablement (TITRE II). Enfin, pour consolider la création de deux ordres juridictionnels, et les ancrer dans la conception française de la séparation des pouvoirs, il a fallu doter les magistrats des deux ordres de garanties statutaires indispensables à l'exercice de leurs pouvoirs juridictionnels (TITRE III).

### TITRE I : L'EMERGENCE D'UN ORDRE JURIDICTIONNEL ADMINISTRATIF

Après la Révolution, le contentieux suscité par les administrations publiques était résolu par l'Administration active elle-même ou par des juridictions administratives étroitement liées à elle à un point que les juristes assimilaient l'Administration à de véritables juges : c'était le système de l'administrateur-juge (**CHAPITRE 1**). Il faudra attendre la **loi du 24 mai 1872** et la célèbre décision **Cadot de 1889** du Conseil d'État pour voir le contentieux administratif s'émanciper pleinement de l'Administration active (**CHAPITRE 2**).

#### CHAPITRE 1 : LE SYSTEME DE L'ADMINISTRATEUR-JUGE

En 1790, l'Assemblée constituante retient la proposition de Jean-Pierre PEZOUS, député du tiers état, de confier le contentieux de l'Administration directement à l'Administration active. La **loi des 16-24 août 1790** et le **décret du 16 fructidor an III** ont eu pour but de soustraire l'Administration au contrôle du juge ordinaire. Le contentieux administratif se règle alors en dehors des tribunaux ordinaires pour être confié à des collèges composés de membres de l'administration (directoire de département, directoire de district ou encore ministres) : c'est la mise en œuvre du célèbre principe « juger l'administration, c'est encore administrer ».

Seules des justifications d'ordre politique peuvent expliquer la prohibition de l'immixtion des juges ordinaires dans l'activité administrative et le « principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire » qui en découle. En effet, la règle de séparation des autorités administrative et judiciaire est présentée comme une conséquence d'un autre principe : celui de la séparation des pouvoirs. L'idée ici est que l'Administration relevant du pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire ne saurait empiéter sur son domaine.

Cette explication connaît naturellement ses limites puisque tous les régimes qui se sont inspirés de la théorie de la séparation des pouvoirs n'ont pas appliqué de règle de séparation entre les autorités administrative et judiciaire. De surcroît, au nom de la séparation des pouvoirs, on aboutit à la confusion de l'Administration (pouvoir exécutif) avec le pouvoir judiciaire puisque l'Administration devient juge et partie à la fois… C'est donc une interprétation très particulière en France de la séparation des pouvoirs qui a abouti à celle des autorités administrative et judiciaire. L'idée est davantage d'accorder un privilège de juridiction à l'Administration, tel que ce privilège existait déjà sous l'Ancien Régime, que de faire respecter de manière rigoureuse la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire[1]. La loi des 16 et 24 août 1790, confirmée par le décret du 16 fructidor an III, témoigne de la méfiance des révolutionnaires vis-à-vis des tribunaux de droit commun (c'est-à-dire les Parlements qui étaient, sous l'Ancien Régime, des Cours de justice locales de dernier ressort). Il y a donc tout simplement une volonté de protéger l'Administration contre les abus observés sous l'Ancien Régime de la part des parlementaires.

# CHAPITRE 2 : LA CONSECRATION DE L'EXISTENCE D'UN JUGE ADMINISTRATIF INDEPENDANT DE L'ADMINISTRATION ACTIVE

Un ordre juridictionnel va progressivement se détacher de l'Administration active :

- La **Constitution du 22 frimaire an VIII (1799)** a porté création, dans son article 52, du **Conseil d'État**.
- La **loi du 28 pluviôse an VIII** (1800) a institué quant à elle, dans chaque département, des **conseils de préfecture**.

Ces institutions ne peuvent encore toutefois être considérées comme des juridictions indépendantes de l'Administration ni même comme des juges de droit commun du contentieux administratif, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, les conseils de préfecture et le Conseil d'État ne sont chargés de rendre que des avis. C'est en effet le préfet au niveau des conseils de préfecture et le chef de l'État au niveau du Conseil d'État qui rendent la décision et qui sont libres de suivre ou de ne pas suivre l'avis formulé. C'est le **système de la justice retenue**.

Ensuite, la création d'une administration juridictionnelle n'a pas mis fin au système de l'administrateur-juge dans la mesure où les ministres demeurent juges de droit commun de l'Administration en premier ressort. En effet, la loi du 28 pluviôse an VIII n'a attribué qu'une compétence d'attribution aux conseils de préfecture qui recouvre principalement deux domaines : le contentieux des travaux publics et celui des contributions directes.

Dans ce système, le Conseil d'État est juge d'appel des décisions rendues par les conseils de préfecture en premier ressort mais également de celles rendues par les ministres pour toutes les autres matières ne relevant pas des conseils de préfecture.

Par conséquent, le système demeure imparfait et toujours marqué par le poids de l'Administration active même si, dans la pratique, les préfets et le chef de l'État ont assez rapidement pris l'habitude de suivre l'avis des conseils de préfecture et du Conseil d'État.

Sous la Seconde République, la loi du 3 mars 1849 a abandonné le système de la justice retenue avant que le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte marque un retour en arrière.

Il a fallu alors attendre la Troisième République et la **loi du 24 mai 1872** pour voir rétabli le **système de la justice déléguée** qui ne sera plus jamais remis en cause.

[1] L'Administration royale s'était dotée progressivement de moyens de juger elle-même les litiges relatifs à son fonctionnement pour échapper aux pouvoirs des Parlements. Pour conforter le privilège de juridiction dont bénéficiait l'Administration, l'édit de Saint-Germain de 1641 a interdit formellement aux Parlements de connaître des litiges concernant « État, administration et gouvernement ». Ces dispositions vont être reprises, de façon plus impérative encore, par les révolutionnaires en 1790.

La décision **Cadot du 13 décembre 1889** va clore ce long processus : **le Conseil d'État devient juge de droit commun en premier et dernier ressort du contentieux administratif**. L'Administration est dépouillée de ses fonctions contentieuses. Les conseils de préfecture demeurent juges d'attribution en premier ressort pour les matières visées par la loi du 28 pluviôse an VIII. Le Conseil d'État est alors juge d'appel de leurs décisions**.**

Le **décret-loi du 30 septembre 1953** remplacera les conseils de préfecture par les **tribunaux administratifs** qui deviendront les nouveaux juges de droit commun en premier ressort du contentieux administratif à la place du Conseil d'État qui, lui, devient juge d'appel de droit commun du contentieux administratif.

L'évolution a enfin été achevée par la **loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987** qui a porté création des **cours administratives d'appel**. À partir de cette date, l'organisation de la justice administrative ressemble à celle de la justice judiciaire puisqu'il existe deux degrés de juridiction : les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel qui exercent une compétence de droit commun en premier ressort et en appel. Au-dessus, figure le Conseil d'État en sa qualité de juge de cassation de tout le contentieux administratif (le Conseil d'État étant parfois juge de premier et dernier ressort ou encore juge d'appel).

# TITRE II : LA REPARTITION DES COMPETENCE ENTRE LES DEUX ORDRES JURIDICTIONNELS

La détermination de la frontière séparant la compétence administrative de la compétence judiciaire implique d'étudier :

- Ce qui ne relève de la compétence ni du juge judiciaire ni du juge administratif (**CHAPITRE I**)
- Les litiges d'ordre administratif qui relèvent de la compétence du juge judiciaire (**CHAPITRE II**)
- Les modes de résolutions des problèmes de compétence entre le juge judiciaire et le juge administratif (**CHAPITRE III**)

## CHAPITRE I : L'INCOMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF ET DU JUGE JUDICIAIRE

Par leur objet, les actes du pouvoir législatif (**SECTION I**) et les actes de gouvernement (**SECTION II**) échappent au contrôle juridictionnel du juge administratif mais aussi du juge judiciaire.

### SECTION I : LES ACTES DU POUVOIR LEGISLATIF

Entrent dans cette catégorie la loi (**I**), les ordonnances de l'article 38 de la Constitution (**II**) et le statut des parlementaires (**III**).

#### I. La loi

La conception française de la séparation des pouvoirs donne compétence au juge administratif pour connaître uniquement d'actes de nature administrative, à l'exclusion de tout acte de nature législative.

**Si le juge administratif n'est pas compétent pour annuler un acte de nature législative, il peut néanmoins, à l'occasion d'un recours formé contre un acte administratif :**

**– En contrôler la conventionnalité** *(CE, Ass. 20 octobre 1989 Nicolo, req. n° 108243).*

**– En contrôler indirectement la constitutionnalité. En effet, s'il ne peut pas en contrôler directement la constitutionnalité en vertu de la théorie de l'écran législatif** *(CE, Sect. 6 novembre 1936 Arrighi)***, il peut**

**néanmoins le faire indirectement grâce à la question prioritaire de constitutionnalité consacrée par l'article 61-1 de la Constitution.**

### I. Les ordonnances de l'article 38 de la Constitution

Ces principes conduisent le Conseil d'État, lorsqu'il est amené à se prononcer sur la légalité d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à se déclarer compétent pour examiner :

- La légalité du refus du Premier ministre d'abroger une telle ordonnance, **dès lors qu'elle n'a pas encore été ratifiée par le Parlement et n'a donc pas encore valeur législative** *(CE, 23 octobre 2002 Laboratoires Juva Santé, req. n°232945).*
- La conventionnalité de la loi de ratification de cette ordonnance *(CE, 17 mai 2002 Hoffer, req. n°232359).*

### II. Le statut des parlementaires

L'immunité juridictionnelle des actes législatifs vaut également pour le **statut des parlementaires**, dès lors *« qu'il se rattache à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement* ». Ainsi, ni le juge administratif ni le juge judiciaire ne sont compétents pour connaître des litiges relatifs au statut des parlementaires *(CE, Ass. 4 juillet 2003 Papon, req. n° 254850).*

## SECTION II : LES ACTES DE GOUVERNEMENT

Nous verrons la qualification d'acte de gouvernement (**I**) puis les conséquences qui en découlent (**II**).

### I. La notion d'acte de gouvernement

**Dans sa célèbre décision « Prince Napoléon** *» (CE, 19 février 1875 Prince Napoléon, req. n° 46707)***, le Conseil d'État a indiqué très clairement qu'il ne suffit pas qu'un acte soit dicté par un intérêt politique pour qu'il soit qualifié d'acte de gouvernement.**

Il n'a cependant donné aucune définition générale qui permettrait de réunir dans une même catégorie tous les actes de gouvernement.

À l'analyse de la jurisprudence du Conseil d'État, il apparaît que **les actes de gouvernement peuvent être regroupés en deux grandes catégories :**

– D'une part, **les actes concernant les rapports d'ordre constitutionnel entre les pouvoirs publics** (**A**)
– D'autre part, **les actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France** (**B**)

#### A. Les actes concernant les rapports d'ordre constitutionnel entre les pouvoirs publics

**En premier lieu**, entrent dans cette catégorie les actes qui intéressent **les rapports d'ordre constitutionnel entre le Président de la République, le Premier ministre et le gouvernement** :

- Le décret de **nomination du Premier ministre** et le décret de **composition du gouvernement** *(CE, 16 septembre 2005 Hoffer, req. n°282171).*
- La décision par laquelle le Président de la République a **mis en application l'article 16 de la Constitution**, ayant eu pour effet de l'habiliter à prendre toutes les mesures exigées par les circonstances et notamment à exercer dans les matières énumérées à l'article 34 de la Constitution le pouvoir législatif et dans les matières prévues à l'article 37 le pouvoir réglementaire *(CE, 2 mars 1962 Rubin de Servens, req. n°55049).*

**En deuxième lieu**, entrent dans cette catégorie les actes qui intéressent les **rapports d'ordre constitutionnel entre l'exécutif et le Parlement :**

- Le décret du Président de la République portant **dissolution de l'Assemblée nationale** *(CE, 20 février 1989 Allain, req. n°98538)*.
- Le décret du Président de la République portant **promulgation d'une loi** *(CE, 3 novembre 1933 Desreumeaux).*
- La décision du Président de la République de s'abstenir de **déférer une loi au Conseil constitutionnel** *(CE, ord. 7 novembre 2001 Tabaka, req. n°239761).*
- La décision du Président de la République de **soumettre au Parlement réuni en Congrès un projet de révision constitutionnelle** *(CE, 22 février 2005 Hoffer, req. n°277842).*
- Le décret du Président de la République décidant de **soumettre un projet de loi au référendum** *(CE, 29 avril 1970, req. n°77651).*
- La décision du Premier ministre de ne pas déposer un projet de loi, alors même que son dépôt était prévu par une loi antérieure *(CE, 29 novembre 1968 Tallagrand, req. n°68938)*.
- Le refus du Premier ministre de proposer au Président de la République une révision constitutionnelle *(CE, 26 février 1992, req. n°109795)*.

Toutefois, ont été considérés comme ne constituant pas des actes de gouvernement :

- Le décret par lequel le Président de la République déclare l'état d'urgence en vertu de la loi du 3 avril 1955, dès lors qu'il n'est pas certain, au moment de l'adoption de ce décret, que le Parlement sera ultérieurement appelé à proroger ce régime d'exception *(CE, 24 mars 2006, req. n° 286834).*
- La décision du Premier ministre de charger un parlementaire d'une mission auprès d'un membre du gouvernement, dès lors qu'une telle décision constitue le premier acte de l'exécution d'une mission administrative *(CE, Sect. 25 septembre 1998 Mégret, req. n°195499).*

**En troisième lieu**, entrent dans la catégorie des actes de gouvernement les actes qui intéressent les **rapports d'ordre constitutionnel entre l'exécutif et le Conseil constitutionnel**, comme la décision du Président de la République de nommer un membre du Conseil constitutionnel *(CE, 9 avril 1999 Mme Ba, req. n° 195616).*

S'agissant de ce dernier point, il importe de noter qu'à l'exception de celles citées ci-avant, les nominations effectuées par le Président de la République ne constituent pas des actes de gouvernement. Ainsi, sont attaquables devant le juge administratif par exemple :

- La nomination du président de la commission de contrôle du découpage électoral *(CE, 13 décembre 2017 Président du Sénat, req. n° 411788).*
- La nomination des membres du Conseil économique et social *(CE, Sect. 17 mai 1957 Simonet).*
- La nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature *(CE, Ass. 17 avril 1953, Falco et Vidaillac).*

**En quatrième lieu**, entrent dans la catégorie des actes de gouvernement les actes qui intéressent les **rapports d'ordre constitutionnel entre le législatif et le Conseil constitutionnel,** comme la décision du Président de l'Assemblée nationale de nommer un membre du Conseil constitutionnel *(CE, 21 janvier 2022, req. n° 460456).*

### B. Les actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France

**En premier lieu**, entrent dans cette catégorie les **actes relatifs aux traités et accords internationaux** :

- **La signature d'un traité** *(CE, Sect. 1er juin 1951 Société des étains et wolfram du Tonkin).*
- La décision de ne pas procéder à la publication d'un traité *(CE, 4 novembre 1970 de Malglaive)*
- Le fait pour l'État d'assortir de **réserves** la conclusion d'un traité ou d'un accord, afin d'exclure ou modifier l'effet juridique de certaines de ses clauses dans leur application à son endroit *(CE, Ass. 12 octobre 2018 SARL Super Coiffeur, req. n°408567).*
- Le refus de l'État de faire droit à une demande tendant à ce que la France dénonce un accord international *(CE, 27 mai 2019, req. n°422069).*

**En deuxième lieu**, entrent dans cette catégorie tous les **autres actes relatifs à la conduite par la France de ses relations internationales :**

- La décision du Président de la République de créer autour de l'atoll de Mururoa une zone de sécurité, ainsi que la décision du même jour de suspendre la navigation maritime dans cette zone pendant la durée des essais nucléaires *(CE, Ass. 11 juillet 1975 Paris de la Bollardière, req. n°92381).*
- La décision du Président de la République de reprendre une série d'essais nucléaires *(CE, Ass. 29 septembre 1995 Association Greenpeace France, req. n°171277).*
- Le vote d'un ministre français au Conseil des communautés européennes, lequel se rattache directement à l'exercice par le gouvernement français de ses compétences diplomatiques *(CE, Ass. 23 novembre 1984 Association « Les Verts », req. n°54359)*.
- La décision du ministre des Affaires étrangères de reconnaître le statut diplomatique d'une institution étrangère, en l'espèce l'Institut pour le commerce extérieur italien *(CE, 30 décembre 2015, req. n°384321).*
- La décision du ministre des Affaires étrangères refusant à une personne, ainsi qu'à sa famille, l'autorisation de séjourner en France en qualité de membre du personnel d'une mission diplomatique étrangère *(CE, 16 novembre 1998, req. n°161188).*
- L'accomplissement de la mission de protection à l'étranger des biens des citoyens français, incombant aux services diplomatiques et consulaires de la France à l'étranger *(CE, 2 mars 1966 Dame Cramencel, req. n°65180).*
- Le refus de soumettre un litige à la Cour internationale de Justice *(CE, 9 janvier 1952 Gény, req. n°92255).*

- La décision gouvernementale d'interdiction faite aux entreprises israéliennes d'exposer dans un salon de l'industrie navale de défense des matériels militaires susceptibles d'être utilisés par les forces armées israéliennes (TC 10 mars 2025 n°4336) ;
- L'objection à l'application d'une résolution internationale prise par le gouvernement français (CE 26 septembre 2025, assa Bloom, N°488335).

La théorie de l'acte de gouvernement connaît cependant d'importantes limites, de nombreux actes étant considérés comme détachables de la conduite des relations internationales de la France.

Ainsi, **en matière d'extradition**, le Conseil d'État considère que sont attaquables :

- Le décret d'extradition *(CE, Ass. 28 mai 1937 Decerf).*
- La décision refusant une demande d'extradition formulée par un État étranger *(CE, Ass. 15 octobre 1993 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, req. n°142578).*

**En matière de ratification des traités (*<u>à ne pas confondre avec la signature des traités</u>*)**, les juges du Palais Royal ont estimé que le juge administratif pouvait contrôler la **régularité de la procédure de ratification d'un traité** *(CE, Ass. 18 décembre 1998, SARL du Parc d'activités de Blotzheim, req. n°181249)*. Un tel moyen relatif à la régularité de la procédure de ratification d'un traité peut être invoqué aussi bien à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir directement formé à l'encontre du **décret de publication** qui en a permis l'introduction dans l'ordre juridique interne, mais aussi **par voie d'exception**, à l'occasion d'un litige mettant en cause l'application de cet engagement international *(CE, Ass. 5 mars 2003 Aggoun, req. n°242860).*

**En ce qui concerne le droit de l'Union européenne**, le Conseil d'État a précisé que **le refus du Premier ministre de notifier une aide d'État à la Commission européenne ne constitue pas un acte de gouvernement** (*CE, Ass. 7 novembre 2008 Comité national des interprofessions des vins à appellations d'origine, req. n°282920).*

Enfin, bien que la signature d'une convention internationale constitue un acte de gouvernement, le Conseil d'État admet, depuis sa célèbre décision « Compagnie générale d'énergie radioélectrique » *(CE, Ass. 30 mars 1966 Compagnie générale d'énergie radioélectrique)*, que l'on puisse engager la **responsabilité sans faute de l'État, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, en cas de préjudice né d'une convention internationale.**

Enfin signalons que le Conseil d'État considère qu'il est possible d'obtenir réparation des conséquences des actes non détachables des relations internationales en recherchant la responsabilité sans faute de l'État même si cette

demande de réparation est soumise à des conditions très strictes (CE, Ass., 24 octobre 2024, Mutuelle centrale de réassurance, n° 465144).

### II. L'acte de gouvernement, un acte insusceptible de recours

L'acte de gouvernement est un acte dont le caractère exceptionnel le met en dehors de tout contrôle juridictionnel.

**Il bénéficie ainsi d'une immunité juridictionnelle qui interdit non seulement d'en contester la légalité mais aussi d'engager la responsabilité pour faute de son auteur. Seule une responsabilité sans faute, pour rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques, peut éventuellement être envisagée** *(cf. notamment : CE, Ass. 30 mars 1966 Compagnie générale d'énergie radioélectrique).*

Cette immunité juridictionnelle devant rester exceptionnelle dans un État de droit, le Conseil d'État n'a eu de cesse de restreindre (sans pour autant y renoncer totalement) la catégorie des actes de gouvernement.

La Cour Européenne des droits de l'Homme a jugé, en ce qui la concerne, que l'irrecevabilité d'une action en justice dirigée contre un acte qualifié en droit interne d'« acte de gouvernement » n'emporte pas nécessairement violation du droit au juge reconnu par l'article 6 de la Conv. EDH *(CEDH, 14 décembre 2006, Markovic c. Italie, n°1398/03).*

## CHAPITRE II : LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE JUGE JUDICIAIRE

Nous venons de voir ce qui ne relève de la compétence ni du juge judiciaire ni du juge administratif.

Nous devons désormais étudier les compétences dévolues au juge administratif (**SECTION II**) puis celles dévolues au juge judiciaire (**SECTION III**). Mais avant cela, il convient d'examiner les modalités de répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire (**SECTION I**).

### SECTION I : LES MODALITES DE REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE JUGE JUDICIAIRE

Le législateur est seul compétent pour répartir les compétences entre les deux ordres de juridiction **(I).** La compétence du législateur ne s'exerce toutefois pas sans limites. Celle-ci doit en effet préserver le champ de compétence de la juridiction administrative constitutionnellement garantie par le Conseil constitutionnel dans sa **décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 « Conseil de la concurrence » (II)**.

#### I. La compétence du législateur pour répartir les compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif

**Le pouvoir réglementaire est compétent uniquement pour répartir les compétences au sein de l'ordre administratif**[2], c'est-à-dire pour déterminer, par exemple, si une matière relève de la compétence du Tribunal administratif en première instance ou du Conseil d'État en premier et dernier ressort.

[2] Voir par exemple le décret n°2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ou encore le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du Code de justice administrative (partie réglementaire) qui modifie la compétence du Tribunal administratif en tant que juge unique.

En revanche, **le pouvoir réglementaire est incompétent pour répartir les compétences entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire**[3]. Il ne peut donc en aucun cas attribuer ou supprimer un champ de compétence d'une juridiction administrative.

Comme le rappelait Guy BRAIBANT dans ses conclusions devant le Tribunal des conflits en 1970, « *dans la tradition républicaine, la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires appartenait au domaine de la loi (CE, Sect. 23 janvier 1953, Avril ; CE, Ass. 16 mars 1956, Garnett). Après l'intervention de la Constitution de 1958* […], *l'assemblée du contentieux du Conseil d'État a maintenu formellement et solennellement les principes traditionnels* ». **La décision de l'Assemblée du Conseil d'État du 30 mars 1962, *Association nationale de la meunerie***, à laquelle fait référence Guy BRAIBANT, a solennellement affirmé « *que, par application de l'article 34 de la Constitution […], c'est au législateur seul qu'il appartient de fixer les limites de la compétence de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire* ».

**Seul le législateur est donc compétent pour fixer les limites de la compétence des juridictions administratives et judiciaires.** Cette compétence découle de l'article 34 de la Constitution disposant que « *la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques* » *(CE, Ass., 30 mars 1962, Association nationale de la meunerie, préc.).*

Une loi peut ainsi venir modifier les règles de compétence de la juridiction administrative, par exemple en transférant certains champs de compétence à la juridiction judiciaire.

Dans ce cas, **le principe est celui de l'application immédiate de la loi nouvelle dès son entrée en vigueur** ; ce qui implique que le changement de compétence est applicable aux instances en cours. Si la juridiction administrative avait déjà été saisie, par exemple, elle devra mettre fin à l'instance en se déclarant incompétente.

En revanche, si le jugement a déjà été rendu par la juridiction désormais incompétente, celui-ci n'est toutefois pas considéré comme ayant été rendu par une juridiction incompétente et fera l'objet des procédures d'appel et de cassation prévues par l'ancien système *(CE, 4 mars 1927, Société l'Économique)*. Autrement dit, on demeure dans l'ordre juridictionnel initialement compétent.

Rien n'empêche toutefois le législateur de déroger au principe de l'application immédiate et de prévoir des mesures transitoires pour faciliter l'entrée en vigueur de la loi (en pratique la loi prévoit souvent des dispositions transitoires pour assurer la sécurité juridique).

On fera enfin deux remarques sur la manière dont le législateur a réparti les compétences entre les deux ordres de juridiction :

- Les lois qui ont pour objet de déterminer les compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire sont éparses et n'ont aucune cohérence entre elles.
- Il y a plus de lois qui attribuent la connaissance de litiges administratifs aux tribunaux judiciaires que de lois qui en attribuent aux tribunaux administratifs. Autrement dit, lorsqu'une loi intervient en matière d'attribution de compétences, elle le fait le plus souvent en faveur du juge judiciaire.

## II. Une compétence du législateur qui doit s'exercer dans les limites de la compétence constitutionnellement réservée à la juridiction administrative

La **décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 « Conseil de la concurrence »** pose deux règles fondamentales :

> « *15. Considérant que les dispositions des articles 10 et 13 de la* ***loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires*** *n'ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle ; que, néanmoins, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs,* ***figure au nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de***

[3] CE, Ass., 30 mars 1962, Association nationale de la meunerie ; Trib. des conflits, 2 mars 1970, Société Duvoir c/SNCF, concl. Braibant.

***puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ;***

*16.* ***Considérant cependant que, dans la mise en œuvre de ce principe, lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé*** *(…)* »

**1)** Dans le premier considérant, **le Conseil constitutionnel a dégagé un PFRLR à partir de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III qui ont posé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Selon ce PFRLR**, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, **relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle.**

Sont visés les recours par voie d'action, c'est-à-dire les recours exercés directement contre de tels actes afin d'en obtenir l'annulation (une annulation contentieuse est toujours rétroactive sauf aménagement prévu par le juge administratif) ou plus modestement la modification totale ou partielle (réformation) de l'acte.

En dégageant un PFRLR selon lequel relève de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique par les autorités administratives, le juge constitutionnel fait apparaître (dans cette décision du moins) les prérogatives de puissance publique (les « ppp ») comme le critère de la détermination de la compétence du juge administratif. Il est important de noter que cette décision vise uniquement les décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique par les personnes publiques et non par les personnes privées, quand bien même ces dernières seraient investies de telles prérogatives.

Le domaine du juge administratif constitutionnellement protégé est donc beaucoup plus réduit que celui qui est aujourd'hui le sien. Cela n'implique aucunement qu'il faille réduire le périmètre de la compétence de la juridiction administrative à son noyau dur (annulation ou réformation des décisions administratives prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique) mais uniquement qu'il existe un champ de compétences au-delà duquel des réformes ne peuvent être effectuées.

**2) Dans le second considérant, le Conseil précise que lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé**, c'est-à-dire celle qui a à connaître le plus grand nombre de litiges dans le domaine donné.

La jurisprudence « Conseil de la concurrence » va connaître des applications concrètes dont l'une, en date du 28 juillet 1989, n'a pas manqué de déclarer **contraire à la Constitution[4] le transfert du contentieux de la reconduite à la frontière au profit du juge judiciaire,** car ne répondant pas à un souci de bonne administration de la justice.

**Décision n° 89-261 DC, 28 juillet 1989, Loi relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France (en ce qui concerne l'article 10) :**

« *21. Considérant que les décisions prises par l'autorité administrative sur le fondement de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ;*

[4] Le Conseil constitutionnel a encore eu l'occasion de censurer d'office une disposition attribuant aux tribunaux de la sécurité sociale (ordre judiciaire) le contentieux d'actes administratifs mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique dans sa décision *n°2001-451 DC, 27 nov. 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.*

*qu'il en va ainsi notamment des mesures de refus d'entrée sur le territoire national visées à l'article 5 de l'ordonnance, des décisions relatives à l'octroi d'une carte de séjour mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, des décisions concernant la délivrance de la carte de résident dans les cas visés respectivement par les articles 14 et 15 de l'ordonnance, de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière d'un étranger se trouvant en situation irrégulière pris en application de l'article 22 de l'ordonnance, de l'expulsion d'un étranger dans les hypothèses définies aux articles 23 à 26 de l'ordonnance, ou de son assignation à résidence en vertu de l'article 28 de l'ordonnance ;*

*22. Considérant que, s'agissant de l'usage par une autorité exerçant le pouvoir exécutif ou par un de ses agents de prérogatives de puissance publique, les recours tendant à l'annulation des décisions administratives relatives à l'entrée et au séjour en France des étrangers relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;*

*23. Considérant que le législateur a, dans le cas particulier de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, entendu déroger, par l'article 10 de la loi déférée, aux règles habituelles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction en se fondant sur la compétence reconnue à l'autorité judiciaire en matière de liberté individuelle et notamment de peines privatives de liberté ainsi qu'en ce qui concerne les questions relatives à l'état des personnes ; qu'il a estimé également qu'un transfert de compétence au tribunal de grande instance statuant en la forme du référé répondait à un souci de bonne administration de la justice ;*

*24. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la Constitution l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; que l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 satisfait à cette exigence en soumettant au contrôle de l'autorité judiciaire toute prolongation au-delà de vingt-quatre heures du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire d'un étranger qui soit n'est pas en mesure de déférer immédiatement à la décision lui refusant l'autorisation d'entrer sur le territoire français soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;*

*25. Considérant toutefois, que la compétence ainsi reconnue à l'autorité judiciaire pour contrôler une mesure de surveillance qui met en cause la liberté individuelle, s'exerce indépendamment du contrôle de la légalité des décisions administratives de refus d'accès au territoire national, de reconduite à la frontière ou d'expulsion ; qu'au demeurant, une mesure de rétention de l'étranger qui est dans l'impossibilité de déférer immédiatement à une décision d'éloignement ne peut intervenir que "s'il y a nécessité absolue" ; que dès lors, la prolongation par l'autorité judiciaire de cette mesure de surveillance ne saurait revêtir un caractère systématique et s'appliquer, tant s'en faut, à tous les cas où il y a intervention d'une décision administrative d'éloignement d'un étranger du territoire national ;*

*26.* ***Considérant que si l'entrée et le séjour irrégulier en France d'un étranger constituent, dans les cas visés aux articles 19 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, une infraction pénale relevant de la seule compétence du juge judiciaire, cette compétence spécifique ne saurait justifier qu'il soit fait échec à la compétence générale du juge administratif dans le domaine de l'annulation des actes de la puissance publique*** *;*

*27. Considérant sans doute qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultante de l'article 13-VI de la loi déférée, certaines catégories d'étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en raison de considérations liées à leur âge ou à leur situation familiale ; qu'en outre, une mesure d'éloignement n'est légalement justifiée que si l'intéressé est de nationalité étrangère ou n'a pas de nationalité ;*

*28. Considérant cependant que les litiges liés à ces situations* ***ne sont pas d'une nature ou d'une fréquence telle qu'ils puissent entraîner une dérogation aux règles normales de compétence*** *; qu'au surplus, en vertu de dispositions identiques à celles du troisième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance, est prohibée l'expulsion des mêmes catégories d'étrangers, hors le cas de la procédure exceptionnelle régie par l'article 26 de l'ordonnance ; que le contrôle de la légalité de semblables mesures ressortit à la compétence du juge administratif ;*

*29.* ***Considérant, par ailleurs, que la bonne administration de la justice commande que l'exercice d'une voie de recours appropriée assure la garantie effective des droits des intéressés ; que, toutefois, cette exigence, qui peut être satisfaite aussi bien par la juridiction judiciaire que par la juridiction administrative, ne saurait à elle seule autoriser qu'il soit porté atteinte à un principe de valeur constitutionnelle*** ».

Il s'infère de ce qui précède que le contentieux des étrangers relève du domaine de compétence du juge administratif constitutionnellement protégé à savoir, l'annulation ou la réformation des actes administratifs ou des décisions administratives émanant d'autorités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique. Partant, s'il doit y avoir une unification du contentieux au nom d'une bonne administration de la justice, cela se ferait au profit du juge administratif principalement compétent pour le contentieux des étrangers et de reconduite à la frontière et non pas au profit du juge judiciaire.

À l'inverse, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion d'appliquer en 1996 sa jurisprudence « Conseil de la concurrence » de manière positive dans le cas du transfert de compétence à la Cour d'appel de Paris de certaines décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications (qui est une autorité administrative indépendante).

Décision n° 96-378 DC, 23 juillet 1996, Loi de réglementation des télécommunications :

*« 23. Considérant qu'en l'espèce les décisions de l'Autorité pourront trancher des litiges relevant du* ***droit de la concurrence ou des différends de nature commerciale ou technique survenus dans la négociation ou l'exécution des conventions d'interconnexion, lesquelles, en vertu de l'article L. 34-8 du code des postes et des télécommunications, constituent des conventions de droit privé*** *; qu'il en sera de même des litiges entre opérateurs s'agissant des possibilités et conditions d'une utilisation partagée entre eux des installations existantes ou des conditions de mise en conformité avec l'article L. 34-4 du même code des conventions relatives à la fourniture de services de télécommunications visés par cet article* *; que la saisine de l'Autorité par l'une ou l'autre des parties est facultative ; qu'au cas où les opérateurs n'auront pas choisi de saisir l'Autorité de régulation, les litiges seront portés selon le cas, soit devant le Conseil de la concurrence et, en cas de contestation, devant la cour d'appel de Paris, soit devant le juge du contrat ; que la loi déférée tend ainsi à unifier, sous le contrôle de la Cour de cassation, l'ensemble des contentieux spécifiques visés aux I et II de l'article L. 36-8 ;*

*24. Considérant que* ***cet aménagement précis et limité des règles de compétence juridictionnelle peut être justifié par les nécessités d'une bonne administration de la justice*** *; que dès lors il ne méconnaît pas le principe à valeur constitutionnelle invoqué par les auteurs de la saisine ; que par suite le grief invoqué doit être écarté. »*

## SECTION II : LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF

La compétence du juge administratif procède de normes constitutionnelles (**I**), législatives (**II**) et jurisprudentielles (**III**).

### I. La compétence du juge administratif déterminée par la constitution

Pour rappel, l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités administratives relève de la compétence de la juridiction administrative, en vertu d'un PFRLR qui a valeur constitutionnelle.

### II. La compétence du juge administratif déterminée par la loi

Trois lois importantes ont attribué des compétences aux juridictions administratives :

- La **loi du 28 Pluviôse An VIII** qui instaure les conseils de préfecture, ancêtres des tribunaux administratifs, et qui réserve en son article 4 la compétence des conseils de préfecture pour connaître du contentieux :
    - Des **travaux publics**
    - Des **ventes d'immeubles de l'État**
    - Des **contributions directes**
    - De la répression des **contraventions de grande voirie**[5]
- Le **décret-loi du 17 juin 1938** qui attribue à la juridiction administrative les **contrats comportant l'occupation du domaine public** même si ces contrats sont passés par les concessionnaires privés de service public[6].
- La **loi n° 86-29 du 9 janvier 1986** portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales qui donne compétence à la juridiction administrative pour connaître des **actions en responsabilité contre l'État du fait des dommages consécutifs aux attroupements et rassemblements**.

Les lois qui attribuent la compétence aux juridictions judiciaires pour connaître de litiges d'ordre administratif sont beaucoup plus nombreuses (cf. *infra*).

## III. La compétence du juge administratif déterminée par la jurisprudence

La compétence exclusive du législateur ne prive pas le juge de déterminer sa propre compétence. Il faut en effet compter sur les normes jurisprudentielles (surtout lorsqu'il s'agit de combler le silence de la loi) et sur l'interprétation que fait le juge des dispositions législatives existantes en la matière. Relèvent par exemple de la compétence du juge administratif (sans protection constitutionnelle), le domaine public **(A)**, les contrats administratifs **(B)**, l'organisation et le fonctionnement du service public **(C)**, la police administrative **(D)** ou encore l'engagement de la responsabilité de l'État **(E)**.

### A. Le domaine public

Seuls les biens des personnes publiques faisant partie de leur domaine public relèvent de la compétence du juge administratif.

Les biens des personnes publiques appartenant à leur domaine privé relèvent de la compétence du juge judiciaire (exemple type : les forêts domaniales).

Dans certains cas, le domaine privé peut accueillir des services publics. C'est notamment le cas dans le domaine de la protection et de la mise en valeur des forêts pour des préoccupations de sauvegarde de l'environnement. Le juge administratif considère que le contentieux de l'activité de service public se détache de la gestion *stricto sensu* du domaine privé et relève donc de la compétence des juridictions administratives (**CE, 3 mars 1975, Courrière**).

La jurisprudence administrative utilise également la notion d'acte détachable de la gestion du domaine privé pour, dans de nombreux cas, redonner compétence à la juridiction administrative. Ainsi, la décision de vendre une parcelle *(CE, 10 mars 1995, Ville de Digne)* ou la décision qui détermine les modalités d'accès des tiers aux dépendances domaniales *(CE, 30 mai 1947, Sussel et Bille)* sont considérées par le juge administratif comme des actes détachables de la gestion du domaine privé et à ce titre relèvent de la compétence du juge administratif**.**

Il en est de même lorsque le domaine privé est le lieu de travaux publics ou d'ouvrages publics lorsque leur finalité n'est pas la simple exploitation du domaine (routes forestières ouvertes à la circulation générale par exemple : *Trib. des conflits, 5 juillet 1999, Menu*).

[5] Ces chefs subsistent aujourd'hui même si cette loi a été abrogée par l'ordonnance du 21 avril 2006 qui porte partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques.
[6] Ce décret-loi a été aboli par la même ordonnance du 21 avril 2006, mais la règle a été reprise par le code précité.

Le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur une demande d'expulsion faite par un sous-concessionnaire du domaine public, que l'on soit dans un cas d'absence de tout titre, ou dans un cas d'expiration du titre *(Cass. 1ère civ., 5 mars 2008, n°07-12.472)* **:**

> « (…) *Attendu que la société Chantier naval de Cap d'Ail (CNCA), actionnaire de la Société du port de plaisance de Cap d'Ail (SPPC), sous-concessionnaire du port de plaisance, a fait assigner cette société devant le tribunal de commerce pour voir ordonner son expulsion de locaux techniques situés sur le port de plaisance et en paiement d'indemnités d'occupation ; que le tribunal de commerce, estimant que le litige concernait l'occupation du domaine public, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; (…)*
> *Mais attendu que relèvent de la compétence des juridictions administratives, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s'élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public ; que celle-ci résulte de l'absence de tout titre d'occupation ou de l'expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu* ; (…) »

### B. Les contrats administratifs

Dès lors qu'un contrat est qualifié de contrat administratif, la juridiction administrative est compétente pour connaître des actions exercées à son encontre ou à l'occasion de son exécution.

Le contrat administratif est soit qualifié en tant que tel par le législateur (exemples des marchés publics, concessions) soit, en l'absence de dispositions législatives, en application des critères de qualification dégagés par le Conseil d'État lui-même.

Il est rappelé que pour qualifier un contrat d'administratif, la jurisprudence s'appuie sur deux critères : le critère organique et le critère matériel.

Est pour le juge dans le silence de la loi un contrat administratif le contrat conclu par au moins une personne publique (critère organique) qui (critère matériel) :

- Confie au cocontractant de l'administration une mission de service public *(CE, 20 avril 1956, Époux Bertin).*
- Ou qui contient des clauses exorbitantes du droit commun *(CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges ; T. confl. 13 oct. 2014, SA AXA France IARD, n° 3963).*
- Ou encore qui est conclu sous un régime exorbitant du droit commun *(CE, 19 janvier 1973, Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant)*.

Les contrats qui associent deux personnes publiques sont présumés administratifs *(Trib. des conflits, 21 mars 1983, Union des assurances de Paris)* sauf si le contrat ne fait naître que des rapports de droit privé.

Inversement, les contrats associant deux personnes privées sont présumés de droit *privé (CE, 13 décembre 1963, Syndicat des praticiens de l'art dentaire du département du Nord).* Dans un arrêt Société de HLM pour Paris du 14 décembre 2009, le Tribunal des conflits a rappelé que « *le contrat conclu entre deux personnes morales de droit privé est présumé être un contrat de droit privé »* dès lors en tout cas qu'elles ont agi pour leur *« propre compte* ». La présomption, qui est simple, peut toutefois être renversée.

Ainsi, le juge administratif est compétent pour contrôler des contrats passés entre deux personnes privées lorsque :

- L'une de ces deux personnes est transparente *(CE, 21 mars 2007, Boulogne Billancourt)* ;
- L'une des deux personnes agit pour le compte d'une personne publique dans le cadre d'un mandat explicite ou implicite (l'hypothèse du mandat administratif est un cas de figure très proche de celui du mandat en droit civil)

- Lorsque l'objet du contrat relève « *par nature* » d'une mission dévolue à *l'État (Trib. des conflits, 8 juillet 1963, Société entreprise Peyrot)* comme c'était le cas en matière d'autoroute avant que le Tribunal des conflits opère en 2015 un revirement de jurisprudence[7].

Le Tribunal des conflits a ajouté un autre cas dans son arrêt du 8 juillet 2013, Société d'exploitation des énergies photovoltaïques : « *les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public* » (contrats de raccordement qui forment un tout avec les contrats d'achat d'électricité).

### C. L'organisation et le fonctionnement du service public

La notion de service public intervient notamment comme critère matériel de répartition des compétences entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires.

Selon que les services publics sont administratifs ou industriels et commerciaux[8], leur contentieux est attribué soit au juge administratif, soit au juge judiciaire.

À cet égard, l'arrêt « **Blanco » du 8 février 1873** du Tribunal des conflits mais, surtout, **les décisions du Conseil d'État « Terrier » du 6 février 1903, « Feutry » du 29 février 1908 et « Thérond » du 4 mars 1910** marquent une étape décisive dans le développement de la compétence de la juridiction administrative. Le principe ici est que tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services publics constitue une opération administrative relevant par sa nature du domaine de la juridiction administrative.

Par la suite, le critère de service public comme critère de détermination de la compétence du juge administratif va connaître une profonde crise. Le coup sera donné par le Tribunal des conflits en 1921[9] *(Trib. des conflits 22 janv. 1921, Société commerciale de l'Ouest africain)* puis par le Conseil d'État en 1938 *(CE, 13 mai 1938, Caisse primaire, aide et protection).*

De manière synthétique, les services publics administratifs gérés par une personne publique ou par une personne privée font l'objet d'une compétence exclusive de la part de la juridiction administrative et sont régis par le droit administratif.

Cette compétence inclut :

- Les litiges avec les agents *(Trib. des conflits, 25 mars 1996, Berkani)*.
- Les litiges avec les usagers *(Trib. des conflits, 15 mars 1999, Mme Pristupa).*
- Les litiges avec les tiers *(Trib. des conflits, 15 novembre 1999, Comité d'expansion de la Dordogne*).

La compétence du juge administratif vaut tant pour le contentieux des actes administratifs unilatéraux ou contractuels que pour les actions tendant à la mise en cause la responsabilité administrative de ce service public administratif.

Inversement, si le service public est industriel et commercial, le droit privé est applicable et la compétence de principe est celle du juge judiciaire que le service soit géré par une personne publique ou par une personne privée. Le juge judiciaire sera en effet toujours compétent pour connaître des relations entre un service public

---

[7] Il résulte en effet de l'arrêt du 9 mars 2015, Rispal c/Société des Autoroutes du Sud de la France « qu'une société concessionnaire d'autoroute qui conclut avec une autre personne privée un contrat ayant pour objet la construction, l'exploitation ou l'entretien de l'autoroute ne peut, en l'absence de conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte de l'État » et « que les litiges nés de l'exécution de ce contrat ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

[8] Sont dits administratifs certains services publics qui sont conformes aux missions fondamentales de l'État et symbolisent la spécificité de la puissance publique. À ce titre, le droit qui les régit ne saurait être le droit commun, mais bien le droit administratif appliqué le cas échéant par les juridictions administratives. À côté de ces services publics administratifs, les services publics industriels et commerciaux conservent une finalité d'intérêt général — sinon il n'y aurait pas qualification de service public — mais ils témoignent de préoccupations plus économiques, plus proches des activités du secteur privé, qui rendent moins légitime l'application d'un droit exorbitant. La distinction entre ces deux types de service public se fait en fonction de critères liés à l'objet du service public, son financement et son organisation : CE, 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques.

[9] Il est néanmoins possible d'observer les prémisses de cette crise dès 1912 dans les conclusions du commissaire du gouvernement Blum sur la décision du CE « Société des granits porphyroïdes des Vosges ».

industriel et commercial et ses usagers *(Trib. des conflits, 1966, Dame Veuve Canasse).* De même, la jurisprudence réserve au juge judiciaire la connaissance des litiges individuels concernant les agents des services publics industriels et commerciaux même lorsqu'ils sont gérés par une personne publique sauf pour le directeur et le comptable public du service public industriel et commercial qui sont soumis aux règles du droit public et à la compétence du juge administratif *(CE, Sect., 8 mars 1957, Jalanques de Labeau).*

La compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges nés de l'organisation ou du fonctionnement d'un service public industriel et commercial connaît d'autres dérogations :

**a)** Le juge administratif redevient compétent pour connaître des actes administratifs unilatéraux ou contractuels pris par une personne privée gérant un service public administratif ou industriel et commercial en utilisant des prérogatives de puissance publique *(CE, 13 janvier 1961, Magnier)*.

**b)** Le juge administratif redevient également compétent pour connaître de la réparation des dommages causés aux tiers (et non pas aux usagers[10] pour lesquels le juge judiciaire reste compétent) par les travaux publics réalisés par une personne privée gérant un service public industriel et commercial *(CE, 25 avril 1958, Dame Veuve Barbaza).* S'applique ici la loi du 28 pluviôse an VIII attribuant à la juridiction administrative la connaissance du contentieux des travaux publics.

**c)** Si, en principe, les personnes privées n'emploient que des agents soumis aux règles de droit privé et au Code du travail, il peut en aller autrement en vertu de certaines lois. Dans ce cas, les litiges opposant des fonctionnaires employés par la personne privée relèvent de la compétence des juges administratifs (cas de certains agents de France Télécom).

**d)** Dans le même sens les litiges d'ordre individuel concernant d'éventuels agents publics en fonction auprès de la personne publique gestionnaire du service public industriel et commercial selon certaines dispositions législatives (cas de la **loi du 2 juillet 1990** pour les agents de La Poste).

**e)** Les recours dirigés contre des actes administratifs réglementaires tendant à l'organisation même ou au fonctionnement du service qu'il soit administratif ou industriel et commercial relèvent de la compétence du juge administratif *(Trib. des conflits, 15 janvier 1968, Époux Barbier).*

### D. La police administrative

Le juge administratif est compétent pour connaître des litiges mettant en cause la police administrative tandis que le juge judiciaire est compétent pour connaître des actions dirigées contre la police judiciaire. Or, l'apport de la jurisprudence est fondamental en matière de distinction entre police administrative et judiciaire et donc en matière de répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire.

Les activités de police administrative se caractérisent par leur caractère préventif et par les objectifs qui leur sont assignés : le maintien de l'ordre public[11].

---

[10] Les relations entre le service public industriel et commercial et ses usagers sont toujours de droit privé : **Trib. des conflits, 17 octobre 1966, Dame Veuve Canasse**. Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action engagée par un usager d'un service public industriel et commercial à moins que le recours ne soit dirigé contre un acte administratif unilatéral témoignant de l'usage de prérogatives de puissance publique : *TC, 19 janvier 1998, Syndicat français de l'Express international*. La jurisprudence retient une conception large de la notion d'usager, ce qui permet de renforcer d'autant le bloc de compétences du juge judiciaire. Ainsi l'utilisateur frauduleux est un usager du service public industriel et commercial : *Trib. des conflits, 5 décembre 1983, Niddam*.

[11] Traditionnellement, la notion d'ordre public recouvre trois éléments, que l'on retrouve notamment dans l'actuelle définition des pouvoirs de police des maires qui figure à l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit de la sécurité publique, de la tranquillité publique et de la salubrité publique. La notion d'ordre public s'est étendue à d'autres domaines, et plus particulièrement à la protection de la moralité publique *(CE, Sect., 18 décembre 1959, Société les films Lutetia ; CE, 8 décembre 1997, commune d'Arcueil)* et au respect de la dignité de la personne humaine *(CE, 27 octobre 1995, commune de Morsang-sur-Orge ; CE, 5 janvier 2007, ministre de l'Intérieur c. Association « Solidarité des Français »).*

Le caractère préventif de la police administrative permet de la distinguer de la police judiciaire qui a un caractère répressif[12].

En effet, la police judiciaire a pour but la recherche des infractions et l'identification de leurs auteurs en vue de l'application de sanctions *pénales (CE, Sect., 11 mai 1951, Consorts Baud – Trib. des conflits, 5 juin 1951, Dame Noualek).*

Juges administratifs et Tribunal des conflits précisent régulièrement la frontière entre les activités de police administrative et de police judiciaire. Il a ainsi été jugé que la police judiciaire concerne aussi bien les infractions commises, que celles qui risquent d'être commises (*Trib. des conflits, 15 janvier 1968, Consorts Tayeb* : pour admettre qu'un acte relève de la police judiciaire il suffit que les agents aient pu estimer que le comportement d'une personne « *était de nature à laisser supposer qu'elle se disposait à commettre un délit* »).

Ainsi, relèvent de la police judiciaire les infractions réellement commises, mais également les infractions supposées.

En vertu de la jurisprudence, le placement en cellule de dégrisement relève de la police administrative *(Trib. des conflits, 18 juin 2007, Ousset).* Selon l'article L. 3341-1 du Code de la santé publique, la personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. Le placement, au cours d'une nuit, d'un individu trouvé en état d'ivresse sur la voie publique, dans une cellule de dégrisement où, quelques heures plus tard, ce dernier a mis fin à ses jours par strangulation, dont l'objet était relatif tant à la protection de la personne concernée qu'à la préservation de l'ordre public, ne relève pas d'une opération de police judiciaire au sens de l'article 14 du Code de procédure pénale. Les litiges relatifs aux dommages pouvant survenir à cette occasion ressortent par conséquent à la compétence des juridictions de l'ordre administratif.

De même, « *la protection d'une personne* » relève en principe de la police administrative, chargée de préserver la sécurité des citoyens et l'ordre public *(Trib. des conflits, 19 oct. 1998, Bolle, veuve Laroche).*

### E. L'engagement de la responsabilité de l'État

Outre la possibilité ouverte d'engager la responsabilité de l'administration pour faute de service *(Trib. des conflits, 8 février 1873, Blanco ; et Trib. des conflits, 30 juillet 1873, Pelletier)*, la responsabilité de l'État peut être engagée du fait du préjudice causé directement par une loi contraire aux engagements internationaux *(CE, Ass., 8 février 2007, Gardedieu).*

Le considérant de principe qui synthétise l'état du droit est le suivant :

> ***«*** *Considérant que la responsabilité de l'État du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France* ***»***.

Deux cas de responsabilité du fait des lois sont ainsi ouverts :

- Le premier cas, fondé sur la rupture d'égalité devant les charges publiques et donc sur la responsabilité sans faute de l'État ;

[12] L'article 14 du Code de procédure pénale précise que la police judiciaire a pour objet de « constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte ». Si le caractère préventif de la police administrative permet de la distinguer de la police judiciaire qui a un caractère répressif, c'est plus précisément l'intention poursuivie par l'auteur de l'acte qui est prise en compte pour qualifier l'opération de police.

- Le second cas, fondé sur la responsabilité de l'État du fait de la contrariété d'une loi à un engagement international sur le terrain de la responsabilité pour faute.

Relève aussi de la compétence des juridictions de l'ordre administratif l'action en responsabilité dirigée contre l'État sur le préjudice résultant du défaut de transposition en droit interne de deux directives communautaires relatives à des contributions indirectes *(Trib. des conflits, 31 mars 2008, Société Boiron).*

La non-transposition d'une directive communautaire dans les délais impartis constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire devant le juge administratif *(CE, Ass., 28 février 1992, Société Arizona Tobacco-Products).*

Allant encore plus loin, le Conseil d'Etat a admis que la responsabilité de l'État peut également être engagée du fait des préjudices causés par l'application d'une loi déclarée inconstitutionnelle sous certaines conditions strictes toutefois.

En effet, par les décisions du CE, Ass., 24 décembre 2019, n° 425981, 425983, 428162, le principe d'une responsabilité de l'État est consacré « en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'application d'une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France » ; jurisprudence reprise et confirmée par le Conseil constitutionnel (CC, n° 2019-828/829 QPC du 28 février 2020).

## SECTION III : LA COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE EN MATIERE ADMINISTRATIVE

Il faut ici distinguer la compétence du juge judiciaire en matière administrative fondée sur des normes constitutionnelles **(I)**, la compétence du juge judiciaire fondée sur des sources législatives **(II)** et la compétence du juge judiciaire fondée sur des règles ou des théories jurisprudentielles **(III)**.

### I. La compétence du juge judiciaire déterminée par la constitution

Le Conseil constitutionnel dans sa décision « Conseil de la concurrence » en date du 23 janvier 1987 consacre un domaine de compétence constitutionnellement réservé au juge administratif tout en admettant deux séries de dérogations à cette compétence dont l'une recouvre la **notion de contentieux « *réservé par nature à l'autorité judiciaire* »**. Faute de précision, c'est la doctrine et la jurisprudence qui ont procédé à l'identification des matières ainsi visées. Or, il convient ici de distinguer le contentieux relatif à l'état des personnes **(A),** celui de la protection de la liberté individuelle **(B)** et de la propriété privée **(C)**.

#### A. L'état des personnes

Les questions relatives à l'état des personnes relèvent du droit privé ; ce qui rend le juge administratif en principe incompétent sur les questions relatives à la filiation, à la capacité ou encore à la nationalité des individus.

En ce qui concerne la nationalité, l'article 29 du Code civil attribue en effet à la seule juridiction civile de droit commun la connaissance des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques :

> *« La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ».*

Cette formulation est interprétée comme donnant compétence au juge judiciaire pour connaître :

- De la validité des certificats de nationalité délivrés par le greffe du tribunal judiciaire
- Du refus du greffe du tribunal judiciaire de délivrer un certificat de nationalité

Le juge administratif reste en revanche compétent pour connaître :

- Des décisions prises en matière de naturalisation
- Des décisions relatives à la réintégration dans la nationalité française
- Des décisions d'opposition à l'acquisition de la nationalité française

### B. Le contentieux des libertés individuelles

C'est l'**article 66 de la Constitution** qui fonde cette compétence. Cet article dispose en effet que : « *Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi* ».

Cette compétence inclut d'abord, comme le prévoit le texte même de la Constitution, la liberté individuelle mais également depuis une **décision du Conseil constitutionnel n° 85-189 DC du 17 juillet 1985 « Loi d'aménagement foncier »**, le **droit de propriété** dont le juge judiciaire est tout autant le « gardien naturel » ainsi que, par extension, **l'état des personnes**.

Le juge judiciaire est compétent pour examiner les conditions de la rétention d'un étranger, dans le cadre de l'examen d'une demande de prolongation de cette rétention : Trib. des conflits 29 décembre 2004, Préfet des Deux-Sèvres c./TGI de Niort :

> « *Considérant que M. Abdala JABER SALEM, ressortissant libyen qui a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et d'une décision le plaçant en rétention administrative dans des locaux situés au commissariat de police de Niort en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a saisi le président du tribunal de grande instance de Niort d'une requête à fin de constat d'huissier sur les conditions de sa rétention ; que, par une ordonnance sur requête en date du 15 décembre 2003, le président de ce tribunal a "autorisé tout huissier à se rendre au commissariat de police de Niort pour y procéder à tout constat dans le local de rétention administrative" ; qu'il a été procédé à un tel constat dans l'après-midi du 15 décembre ; que le PRÉFET DES DEUX-SÈVRES a fait assigner M. Abdala JABER SALEM en référé devant le président du tribunal de grande instance de Niort afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance ; que le président du tribunal de grande instance de Niort a rejeté le déclinatoire de compétence dont il était saisi ;*
>
> *Considérant que dès lors que le président du tribunal de grande instance de Niort était seulement saisi à titre gracieux, sur le fondement de l'article 812 du nouveau Code de procédure civile, d'une demande de constat et alors que ce constat pouvait, le cas échéant, être produit devant le juge judiciaire à l'occasion d'une éventuelle prolongation du maintien dans les locaux décidée sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et n'était ainsi pas manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige relevant de la compétence de l'autorité judiciaire, c'est à tort que le PRÉFET DES DEUX-SÈVRES a présenté devant ce juge un déclinatoire de compétence puis a élevé le conflit* ».

Une théorie jurisprudentielle illustre avec plus de force le principe de la compétence exclusive du juge judiciaire en matière de liberté individuelle et du droit de propriété : la **théorie de la voie de fait** (T. confl. 17 juin 2013, *Bergoend c/ ERDF Annecy Léman*, req. n° 3911).

### C. Le contentieux du droit de propriété

De nombreux arrêts rappellent de manière solennelle que « *la sauvegarde de la liberté individuelle et la protection de la propriété privée rentrent essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire* » (Trib. des conflits, 18 décembre 1947, Hilaire)**.**

Jusqu'à l'arrêt du Tribunal des conflits du 17 juin 2013 *(Bergoend c/ ERDF Annecy Léman)*, la voie de fait se définissait comme l'acte de l'administration portant au droit de propriété ou à une liberté fondamentale une atteinte si grave qu'il en perdait son caractère administratif et relevait du contrôle exclusif du juge judiciaire tant pour faire cesser la voie de fait que pour en prévenir la survenance ou encore condamner l'administration à la réparation de l'ensemble des dommages. Aujourd'hui la voie de fait est l'acte de l'administration qui éteint définitivement le droit de propriété ou qui porte atteinte à une liberté individuelle.

Même si elle ne figure pas dans l'article 66 de la Constitution, la compétence du juge judiciaire pour connaître du contentieux relatif au droit de propriété est le fruit d'une longue tradition jurisprudentielle et législative ; tradition que le Conseil constitutionnel a érigée en principe à valeur constitutionnelle.

Il entraîne au profit du juge judiciaire toute une série de compétences :

- En matière d'expropriation : seul le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur le montant de l'indemnisation et pour prononcer le transfert de propriété
- En matière de détermination des indemnités de réquisition
- En matière de détermination des indemnités dues en compensation de l'institution de servitudes grevant les immeubles
- En matière d'exercice du droit de préemption dès lors qu'il n'y a pas d'accord sur le prix du bien préempté.

## II. <u>La compétence du juge judiciaire déterminée par la loi</u>

La compétence du juge judiciaire par détermination de la loi est particulièrement large. En voici quelques exemples.

### A. <u>La loi du 8 mars 1810</u>

La loi du 8 mars 1810, confirmée par une ordonnance législative du 23 octobre 1958, qui confère aux tribunaux judiciaires l'indemnisation des personnes qui font l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique [13] ; cette attribution s'expliquant par le fait que, comme susindiqué, le juge judiciaire est traditionnellement considéré comme le garant de la propriété privée.

### B. <u>La loi du 5 avril 1937</u>

La **loi du 5 avril 1937** en vertu de laquelle la **responsabilité de l'État devant les juridictions judiciaires est substituée à celle des membres de l'enseignement public**[14] (ou même à celle d'un établissement privé s'il est sous contrat d'association) sous la surveillance desquels se trouvaient des élèves, que les faits dommageables aient eu lieu pendant la scolarité ou en dehors de celle-ci.

Cette loi est codifiée à l'article L. 911-4 du Code de l'éducation :

> « *Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'État est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.*

[13] Il y a une phase administrative et une phase judiciaire. La phase administrative consiste à attaquer en excès de pouvoir la déclaration d'utilité publique et éventuellement les arrêtés de cessibilité subséquents, et une phase judiciaire qui a pour objet d'indemniser les personnes expropriées. Les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents pour transférer la propriété et pour indemniser les expropriés de leurs préjudices matériels et directs.

[14] La notion de membre de l'enseignement est largement interprétée à l'heure actuelle puisque relève de la loi de 1937 par exemple un agent communal accompagnant en tant que moniteur une classe de neige : *Trib. des conflits, 15 février 1999, Époux Martinez***.**

*Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdits par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.*

*L'action récursoire peut être exercée par l'État soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.*

*Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'État pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.*

*L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'État, ainsi responsable du dommage, est portée devant le Tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente.*

*La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis* ».

Cette loi est interprétée dans un sens large puisqu'elle couvre les dommages causés à un élève et ceux causés par un élève *(Trib. des conflits, 31 mars 1950, Delle Gavillet).*

La circonstance que la responsabilité de l'État se substitue à celle de l'enseignant devant les tribunaux civils ne signifie nullement que l'État est responsable dès qu'il y a un accident. L'État n'est responsable que si la responsabilité de l'enseignant est elle-même engagée à la suite d'une faute dont la preuve incombe à la victime. La substitution de l'État n'a donc aucun caractère d'automaticité. Ainsi, le mécanisme ne vaut que tant que l'enseignant a commis une faute (défaut de surveillance, manque de vigilance, participation active au fait dommageable par violence ou par maladresse par exemple).

La loi de 1937 peut être écartée lorsque la victime invoque un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ou s'il invoque un dommage de travaux publics et non pas une faute d'un membre de l'établissement *(Trib. des conflits, 31 mars 1950, Delle Gavillet)*. De même, il a été jugé que la responsabilité légale de l'État ne pouvait être engagée devant le juge judiciaire si les préjudices causés aux enfants résultent d'un défaut de surveillance d'employés communaux de la restauration scolaire dont la mission ne comportait aucune fin éducative ; seule la responsabilité de la commune peut être alors engagée devant le juge administratif *(Trib. des conflits, 30 juin 2008, Préfet des Alpes-Maritimes c./Caisse régionale Groupama)***.**

### C. La loi du 31 décembre 1957

La **loi du 31 décembre 1957** qui attribue aux juges judiciaires la compétence pour connaître des conséquences dommageables des accidents de véhicules[15], qu'ils soient privés ou administratifs. La loi précise que ce sont les règles du Code civil qui seront appliquées et que la responsabilité des personnes publiques est substituée à celles de leurs agents, auteurs des dommages dans l'exercice de leurs fonctions.

Le législateur prévoit toutefois que la loi ne s'applique pas quand est visée une dépendance du domaine public. Dans ce cas en effet, la notion « plus attractive » de domaine public l'emporte et entraîne par voie de conséquence la compétence du juge administratif qui est le gardien naturel du domaine public.

[15] La notion de véhicule est une notion extensive : c'est ce qui a vocation principale à se déplacer, que ce soit de façon autonome ou sous l'effet d'une traction, ou d'une propulsion extérieure. Qualité accordée aux automobiles, motos, bateaux, avions, vélos, engins de chantier à moteurs, ponts roulants, charrettes.
En revanche, un conteneur à ordures ménagères déplacé par le vent n'a pas été reconnu comme véhicule puisqu'il n'a pas vocation principale à se déplacer *(CE, 7 juin 1999, OPHLM d'Arcueil Gentilly).* Ainsi, le vrai critère, c'est la vocation à se déplacer.

La loi ensuite ne s'applique pas quand est en cause la mise en jeu de la responsabilité sur un autre terrain que la responsabilité délictuelle qu'elle prévoit. Échappe ainsi la responsabilité contractuelle : si l'indemnisation de l'accident est prévue dans les clauses contractuelles, cela va entraîner la compétence du juge du contrat. De même si est en jeu la responsabilité sans faute sur le terrain des collaborateurs occasionnels du service public ou des régimes particuliers de mise en jeu de la responsabilité délictuelle (défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, mauvais fonctionnement d'un service public, régime spécial de responsabilité des élus). Dans tous ces cas, ce sera le juge administratif qui retrouvera sa compétence « naturelle ».

Par un arrêt du *Tribunal des conflits, 12 février 2001, Commune de Courdimanche,* a été recherchée (comme cela est fait au demeurant en matière de police) « la phase dominante » de l'opération pour déterminer la compétence du juge alors qu'étaient en cause des véhicules au sens de la loi de 1957.

Dans cette affaire, le dommage était causé par des nuages de poussière provenant d'un chantier public ayant causé des préjudices aux cultures. Les poussières avaient deux origines : d'une part les engins de transport du chantier, principalement des camions qui transportaient des gravats et, d'autre part, des installations fixes et engins qui eux ne sont pas mobiles, mais qui dégagent aussi beaucoup de poussière. Le Tribunal des conflits, au lieu de scinder en deux ce qui revenait d'une part aux camions et d'autre part aux engins et installations fixes, a décidé de raisonner comme il tente de le faire de plus en plus quand l'occasion se présente par « grands blocs de compétence » et a décidé qu'ici la phase dominante étant celle des engins fixes, l'ensemble du litige devait être confié au juge administratif.

Enfin et de même, par un arrêt de la *Cour de cassation, 1ère civ., 23 février 2012, n° 10-27.336,* le juge administratif a été reconnu seul compétent pour connaître d'une action en réparation des dommages résultant des nuisances sonores provoquées par les vols d'aéronefs atterrissant et décollant d'une base aéronautique navale. Estimant être victimes de nuisances sonores, les résidents d'un lotissement avaient fait assigner l'agent judiciaire du Trésor et le préfet du Var afin de voir interdire le survol de leurs propriétés par des hélicoptères de la base aéronautique navale d'Hyères. La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'agent judiciaire du Trésor au profit des juridictions administratives, en estimant que l'ouvrage public aéroportuaire n'était nullement en cause, seuls les véhicules que sont les hélicoptères étant visés comme fauteurs du trouble allégué. La Cour de cassation a, au contraire, estimé que les juridictions judiciaires étaient incompétentes pour connaître du litige, le préjudice invoqué trouvant sa cause déterminante dans l'existence et les conditions de fonctionnement de l'ouvrage public.

### D. Autres exemples

Presque tous les systèmes prévus par le législateur de garantie de dommages qui résultent des risques sociaux prévoient la compétence du juge judiciaire :

- **Loi du 3 janvier 1977** sur l'indemnisation des victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et dont les auteurs restent inconnus ou sont insolvables ;
- **Loi du 9 septembre 1986** sur l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme ;
- **Loi du 31 décembre 1991** qui indemnise les victimes d'une transfusion sanguine contaminée par le virus du SIDA (indemnisation automatique sans faute par l'État devant un fonds d'indemnisation)[16] ;
- **Loi du 23 décembre 2000** relative aux victimes de l'amiante : le fonds d'indemnisation de l'amiante, qui a le statut d'établissement public, rend des décisions pouvant faire l'objet d'un recours direct devant la cour d'appel territorialement compétente.

C'est une tendance assez prononcée, surtout ces dernières années, à chaque fois qu'une catastrophe s'abat sur une partie de la population, le législateur prévoit son indemnisation par le biais d'un fonds d'indemnisation. Une telle conception correspond à une idée de socialisation du risque que le Conseil d'État a illustré dans son rapport annuel de 2013.

[16] *Trib. des conflits, 28 février 2011, Consorts Laugeais* **:** l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 a transféré au juge administratif le contentieux des dommages provoqués par les transfusions sanguines. Toutefois, elle a maintenu la compétence des juridictions judiciaires saisies antérieurement à son entrée en vigueur. Dans un arrêt du 28 février 2011, le Tribunal des conflits a précisé que cette exception ne s'appliquait que dans le cas où le juge judiciaire était saisi à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

## III. La compétence du juge judiciaire déterminée par la jurisprudence

Seront examinées tour à tour la théorie de la voie de fait **(A)**, l'emprise **(B)** et les circonstances dans lesquelles l'autorité administrative agit à l'instar d'une personne privée **(C)**.

### A. La théorie de la voie de fait

La théorie de la voie de fait est dégagée dans l'arrêt du *Tribunal des conflits, Action française du 8 avril 1935***.**

Sur le fondement de cet arrêt, le Tribunal des conflits considérait, de façon constante, que la voie de fait, lorsqu'elle était avérée, était une exception au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.

La voie de fait était caractérisée par l'atteinte grave soit au droit de propriété soit à une liberté fondamentale par l'administration.

> *« (…) il n'y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière,* ***portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale,*** *soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative »* (Trib. des conflits, 23 octobre 2000, M. B. c./ministre des Affaires étrangères).

Le Tribunal des conflits a modifié son considérant de principe en remplaçant la notion « *d'atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale* » par celle « ***d'atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction du droit de propriété*** **»** (Trib. des conflits, 17 juin 2013 Bergoend c./Société ERDF Annecy).

Ce faisant, le champ de la notion de voie de fait s'est considérablement réduit entraînant avec lui un élargissement de la compétence du juge administratif en ce domaine.

**Il n'y a à présent voie de fait de la part de l'administration justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation que dans la mesure où l'administration :**

**– Soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété[17] ;**

**– Soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.**

Cette évolution jurisprudentielle paraît assez logique puisque, depuis la **loi n° 2000-597 du 30 juin 2000**, le juge administratif est compétent pour ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale[18].

### B. La théorie de l'emprise irrégulière

[17] Cette propriété peut être aussi bien immobilière que mobilière. Toutefois, en cas d'expulsion ordonnée en raison de l'urgence à prévenir la survenance d'un dommage imminent, l'exécution régulière du jugement d'expulsion ne peut donner lieu à voie de fait, même si elle implique la destruction de biens meubles appartenant aux personnes expulsées *(T. confl. 11 mars 2024, n° C4301)*.
[18] V. art. L. 521-2 du Code de justice administrative.

À la suite de cette nouvelle définition de la voie de fait, le Tribunal des conflits a tiré les conséquences sur la répartition traditionnelle des compétences en matière d'emprise irrégulière[19] *(T. des conflits, 9 déc. 2013, Ép. Panizzon c./Commune de Saint-Palais-sur-Mer).*

L'emprise, avant l'arrêt du Tribunal des conflits Époux Panizzon c./Commune de Saint-Palais-sur-Mer en date du 9 décembre 2013, se caractérisait par l'existence d'une **dépossession d'un droit réel immobilier par l'administration empêchant son propriétaire de l'utiliser** :

- **Si l'emprise était régulière**, c'est-à-dire si l'administration opérait conformément aux règles légales, l'indemnisation de l'emprise relevait de la **compétence du juge administratif** *(CE, Sect., 1961, Werquin).*
- Au contraire, **si l'emprise était irrégulière**, l'indemnisation relevait de la **compétence du juge judiciaire** qui était seul compétent pour engager la responsabilité de l'administration et statuer sur l'ensemble des préjudices résultant de cette occupation *(TC, 1949, Société Hôtel du vieux Beffroi).*

Dans le prolongement de l'arrêt Bergoend en date du 17 juin 2013 qui restreint la voie de fait[20], le Tribunal des conflits a tiré les conséquences en matière d'emprise irrégulière.

**Lorsqu'une décision de l'autorité administrative porte atteinte à la propriété privée ou au droit de propriété sans l'éteindre, le juge administratif est compétent.**

**Le juge administratif est compétent :**

**– Pour statuer sur le recours en annulation d'une décision portant atteinte à la propriété privée et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration**

**– Et pour connaître des conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative.**

### C. Les circonstances dans lesquelles l'administration est réputée agir à l'instar d'une personne privée

Le juge judiciaire est compétent pour connaître des dommages rattachables à un contrat de droit privé **(1)** ou encore pour tout ce qui touche à la gestion du domaine privé de l'administration **(2)**.

#### 1) Le contentieux des dommages rattachables à un contrat de droit privé

Un accident causé par un ouvrage dépendant de l'ensemble immobilier d'un office public HLM à l'enfant d'un locataire se rattache au contrat de bail privé et l'action en indemnisation du dommage relève des tribunaux judiciaires :

Trib. des conflits, 24 mai 2004, Consorts Garcia c./OPHLM de l'Aude :

> *« Considérant que Mme GARCIA était locataire, à la date de l'accident mortel dont a été victime, à l'âge de 5 ans, sa fille Deborah, de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Aude ; que l'accident évoqué ci-dessus est survenu en raison de l'entretien défectueux, incombant à l'office, d'un lampadaire extérieur éclairant l'ensemble immobilier où résidait la victime ;* ***que dès lors que cet ouvrage, propriété de l'office, constitue une dépendance des locaux dont la jouissance résultait du bail de droit privé conclu***

[19] L'emprise peut être régulière (expropriation) ou irrégulière. Seul le juge administratif est compétent pour vérifier la régularité de l'emprise : *Trib. des conflits, 1949, Société Rivoli-Sébastopol.*

[20] Depuis l'arrêt du Tribunal des conflits en date du 17 juin 2013 en effet, le champ de la voie de fait a été restreint. Si le manque de droit et le manque de procédure ont été maintenus (critère de la dénaturation), il faut désormais soit une atteinte à la « liberté individuelle » (au lieu d'une liberté fondamentale), soit une « extinction du droit de propriété » (au lieu d'une atteinte au droit de propriété). La Cour de cassation a repris, à son tour, les principes de l'arrêt Bergoend (*Cass. 13 mai 2014, Commune d'Uzerche, n°12-28248*) : « *Attendu qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative* ».

***entre Mme GARCIA et l'office, l'action engagée par les Consorts GARCIA contre ce dernier en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de cet accident mortel ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé mentionné plus haut et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire****. ».*

Contrat de droit privé de l'administration relevant de la compétence judiciaire dès lors qu'un tel contrat n'a ni pour objet de faire participer le cocontractant à l'exécution d'un service public administratif ni ne comporte de clause exorbitante du droit commun :

Trib. des conflits, 21 mai 2007, SA Codiam :

*« Considérant que par lettre du 17 décembre 1999, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a fixé au 31 décembre 2000 le terme de la convention portant sur la gestion et l'exploitation d'un réseau d'appareils de télévision mis à la disposition des malades de l'hôpital Avicenne (à Bobigny, en Seine–Saint-Denis), qui avait été conclue avec la société Codiam jusqu'au 31 décembre 2002 ; que cette société a demandé l'indemnisation du préjudice causé par cette rupture anticipée ;*
***Considérant que le contrat dont il s'agit n'a pas pour objet de faire participer la Codiam à l'exécution du service public administratif ; que conclut seulement pour les besoins du service public, il ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun*** *; que la circonstance qu'il autorise le prestataire à occuper un local spécialement aménagé dans l'hôpital n'a pas pour effet de lui conférer la nature d'un contrat d'occupation du domaine public ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige né de sa résiliation ; (compétence de la juridiction judiciaire) ».*

De même, un contrat de transaction conclu par une personne publique constitue en principe un contrat de nature civile dont il appartient à la juridiction judiciaire de connaître, sauf si elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique ou aboutit à la participation du cocontractant à une mission de service public, et sauf si la transaction litigieuse a trait à des différends qui ressortissent à l'évidence à la compétence du juge administratif *(Trib. des conflits, 18 juin 2007, Société Briançon Bus).*

2) Le contentieux relatif au domaine privé de l'administration

Comme toute personne juridique, physique ou morale, les personnes publiques sont titulaires de droits et d'obligations et disposent d'un patrimoine appelé le domaine dont la nature varie. Le domaine des personnes publiques peut en effet être soit public soit privé.

Le juge administratif est compétent pour connaître du domaine public tandis que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au domaine privé de ces dernières.

Aussi, les agents recrutés par une personne publique pour participer à la gestion de son domaine privé sont soumis à un régime juridique de droit privé dont il revient au seul juge judiciaire de connaître *(Trib. des conflits, 15 janvier 2007 Mme Ourahmoune c./Ville de Paris).*

# CHAPITRE III : LE REGLEMENT DES PROBLEMES DE COMPETENCE ENTRE LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE JUGE JUDICIAIRE

Comme nous venons de le voir, la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire n'est pas toujours chose aisée.

Les problèmes de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire peuvent être résolus :

- Soit directement par le juge administratif ou le juge judiciaire, en l'absence de conflits entre eux, grâce à la question préjudicielle (**SECTION I**)
- Soit, en cas de conflit entre eux, par l'intervention du Tribunal de conflits (**SECTION II**)

## SECTION I : LES QUESTIONS PREJUDICIELLES ENTRE LE JUGE JUDICIAIRE ET LE JUGE ADMINISTRATIF

Il importe de définir la notion de question préjudicielle (**I**) avant d'étudier les questions préjudicielles posées par le juge judiciaire au juge administratif (**II**) puis celles posées par le juge administratif au juge judiciaire (**III**).

### I. La notion de question préjudicielle

À la lecture de la définition de la notion de question préjudicielle (**A**), il apparaît que celle-ci doit répondre à deux conditions (**B**) et qu'elle doit être distinguée de la question préalable (**C**).

#### A. La définition de la question préjudicielle

La question préjudicielle est une question présentant une difficulté sérieuse à laquelle la juridiction saisie doit répondre afin de pouvoir trancher la question principale qui lui est soumise, mais qu'elle ne peut, en l'absence de compétence, trancher elle-même, de telle sorte qu'elle doit surseoir à statuer dans l'attente que la juridiction compétente pour en connaître l'ait résolue.

#### B. Une question devant répondre à deux conditions

Pour qu'elle puisse répondre à la qualification de question préjudicielle, la question soulevée doit satisfaire à deux conditions :

- **Sa résolution est nécessaire pour trancher le litige**
- Sa résolution présente une **difficulté sérieuse :**
    - L'article R. 771-2 du CJA dispose que « *Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une **difficulté sérieuse** et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle* ».
    - L'article 49 du Code de procédure civile dispose quant à lui : « *Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une **difficulté sérieuse** et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du Code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle* ».

#### C. La différence entre question préalable et question préjudicielle

Dans les deux cas, la juridiction saisie ne peut trancher la question principale qui lui est soumise qu'après avoir résolu la question préalable.

Toutefois, **alors que la juridiction saisie est compétente pour résoudre elle-même la question préalable, elle ne l'est pas pour résoudre la question préjudicielle**.

### II. Les questions préjudicielles du juge judiciaire au juge administratif

Les questions préjudicielles posées par le juge judiciaire au juge administratif concernent essentiellement la légalité (**A**) et l'interprétation (**B**) des actes administratifs.

#### A. La légalité des actes administratifs

Contrairement au juge pénal (**2**), le juge civil (**1**) a, en principe, l'obligation de poser une question préjudicielle au juge administratif en cas de question relative à la légalité d'un acte administratif.

3) Juge civil

Le principe (**a**) selon lequel le juge civil a l'obligation de poser une question préjudicielle au juge administratif en cas de question relative à la légalité d'un acte administratif connaît des limites (**b**) et des exceptions (**c**).

a) Le principe de l'obligation pour le juge civil de poser une question préjudicielle au juge administratif

En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les recours tendant à l'annulation ou à la réformation des actes administratifs, c'est-à-dire des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.

Il résulte également de ce principe que lorsqu'un moyen sérieux relatif à la légalité d'un acte administratif est soulevé devant le juge civil, celui-ci doit poser une question préjudicielle au juge administratif, qui est seul compétent pour statuer sur ce moyen et apprécier la légalité de l'acte administratif en cause. Ce principe a été posé par la jurisprudence quasi centenaire « Septfonds » de 1923 (TC 16 juin 1923 Septfonds contre Cie des chemins de fer du Midi, req. n°00732) :

> « *Considérant que l'arrêté du 31 mars 1915 a été pris par le ministre de la Guerre, de concert avec le ministre des Travaux publics, en vertu de ces textes ; que****, s'il constitue un acte administratif*** *en raison du caractère des organes dont il émane* ***et si dès lors, à ce titre, il appartient à la juridiction administrative seule d'en contrôler la légalité*** ».

b) Les limites à l'obligation pour le juge civil de poser une question préjudicielle au juge administratif

Obliger le juge civil à poser une question préjudicielle au juge administratif en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif a pour effet d'alourdir les délais de jugement.

Partant, comment conjuguer le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires avec le droit qu'a tout justiciable d'obtenir que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable ?

**Pour concilier ces principes, le Tribunal des conflits a posé, dans sa** *décision SCEA du Chéneau (TC 17 octobre 2011 SCEA du Chéneau, req. n°C 3828),* **deux limites à l'obligation pour le juge civil de poser une question préjudicielle au juge administratif :**

**1) Le juge civil est dispensé de l'obligation de poser une question préjudicielle, quel que soit le moyen de légalité soulevé contre l'acte administratif, lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.**

**2) Le juge civil est également dispensé de l'obligation de poser une question préjudicielle, lorsque le moyen de légalité a trait au défaut de conformité de l'acte administratif au droit de l'Union européenne. Dans ce cas, le juge civil « *doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle* ».**

→ Pour un exemple d'application de la 1re limite, *cf. TC 16 juin 2014, req. n°C 3953* : En l'espèce, le juge civil devait déterminer à titre principal s'il y avait lieu de déclarer ou non une vente parfaite, dans le cas d'une communauté d'agglomération qui, après fixation judiciaire du prix de vente qu'elle estimait trop élevé, avait renoncé à exercer son droit de préemption. Pour répondre à cette question, le juge civil devait au préalable statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de la renonciation à l'exercice du droit de préemption. Or, même si la décision portant renonciation à l'exercice du droit de préemption constitue un acte administratif, le Tribunal des conflits a jugé que le juge civil n'avait pas l'obligation de demander au juge administratif de statuer, par la voie de la question préjudicielle, sur la légalité de cet acte administratif. En effet, il a rappelé que le juge civil pouvait statuer lui-même sur cette question, dès lors qu'« *il résulte d'une jurisprudence établie du Conseil d'État que la décision par laquelle une personne publique renonce à exercer son droit de préemption à l'expiration du délai légal de deux mois après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive fixant le prix de la cession est entachée d'illégalité* ». Autrement dit, il apparaissait manifeste, au vu de cette jurisprudence établie, que le moyen tiré de l'illégalité de la renonciation à l'exercice du droit de préemption

devait être accueilli par le juge civil.

c) Les exceptions légales à l'obligation pour le juge civil de poser une question préjudicielle au juge administratif

Le législateur peut déroger au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et autoriser le juge civil à statuer directement sur la légalité d'un acte administratif, sans avoir à poser une question préjudicielle au juge administratif.

Par exemple, le Tribunal des conflits a jugé qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 211-4 du Code des ports maritimes et de l'article 285 du Code des douanes « **qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire**, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation concernant le paiement d'une redevance constitutive du droit de port, fondée sur une prétendue illégalité des textes instituant cette redevance et fixant son montant, **de se prononcer sur leur légalité** » *(TC 6 juillet 2015 SARL Port Adhoc Leucate, req. n°C 4012).*

4) Juge pénal

**L'article 111-5 du Code pénal dispose que « *les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis* ».**

**En introduisant ces dispositions dans le nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, le législateur a entendu expressément déroger, au nom de l'indépendance du juge pénal, au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et autoriser le juge pénal à statuer directement sur la légalité d'un acte administratif, réglementaire ou individuel, sans avoir à poser une question préjudicielle au juge administratif.**

Le législateur a mis fin à la célèbre jurisprudence **« Avranches et Desmarets »** *(TC 5 juillet 1951, req. n°01187)*, qui imposait au juge pénal de poser une question préjudicielle au juge administratif, en cas d'appréciation de la légalité d'un acte administratif non réglementaire :

> « *Considérant qu'il résulte de la nature de la mission assignée au juge pénal que celui-ci a, en principe, plénitude de juridiction sur tous les points d'où dépend l'application ou la non-application des peines ;* ***qu'il lui appartient****, à cet effet, non seulement d'interpréter, outre les lois, les règlements administratifs, mais encore* ***d'apprécier la légalité de ceux-ci****, qu'ils servent de fondement à la poursuite ou qu'ils soient invoqués comme moyen de défense ;* ***que la compétence de la juridiction pénale ne connaît de limite, en ce domaine, que quant à l'appréciation de la légalité des actes administratifs non réglementaires****, cette appréciation étant, sauf dans le cas de prescription législative contraire, réservée à la juridiction administrative en vertu de la séparation des pouvoirs* ».

À titre d'exemple, le juge pénal est désormais compétent, en cas de poursuite pour conduite malgré invalidation du permis de conduire, pour statuer sur le moyen tiré par le prévenu de l'irrégularité des décisions de retrait de points ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire.

## B. L'interprétation des actes administratifs

Contrairement au juge civil (**1**), le juge pénal (**2**) n'a jamais l'obligation de poser une question préjudicielle au juge administratif en ce qui concerne l'interprétation des actes administratifs.

5) Juge civil

**Depuis l'arrêt Septfonds de 1923** *(TC 16 juin 1923 Septfonds, req. n°00732***), le juge civil a compétence pour interpréter les actes administratifs de nature réglementaire.**

**En revanche, il n'est pas compétent pour interpréter les actes administratifs individuels et doit donc, dans ce cas, poser une question préjudicielle au juge administratif.**

6) Juge pénal

Contrairement au juge civil qui n'est compétent que pour interpréter les actes administratifs réglementaires, **le juge pénal est, en vertu de l'article 111-5 du Code pénal, compétent pour interpréter les actes administratifs aussi bien réglementaires qu'individuels**.

## III. Les questions préjudicielles du juge administratif au juge judiciaire

Les questions préjudicielles posées par le juge administratif au juge judiciaire sont relativement rares. Elles interviennent essentiellement en matière de propriété (**A**) et d'état des personnes (**B**). Il peut arriver parfois que le juge administratif pose également au juge judiciaire une question préjudicielle relative à la validité ou l'interprétation d'une convention de droit privé (**C**).

### A. La propriété des biens

**Seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier si une personne publique (ou privée) est propriétaire d'un bien. En revanche, seul le juge administratif est compétent pour déterminer si le bien dont une personne publique est propriétaire appartient à son domaine public.**

Il en résulte que lorsqu'il est confronté à une question relative à la propriété d'un bien, le juge administratif doit poser une question préjudicielle au juge judiciaire. À l'inverse, lorsque le juge judiciaire est confronté à une question de domanialité publique, c'est lui qui doit poser une question préjudicielle au juge administratif.

Voici des arrêts illustrant clairement cette distinction :

- « *Que, de même, la délibération du conseil municipal du 27 mars 1961 n'a pu avoir eu pour effet d'incorporer le chemin n° 102 dans le domaine public de la commune que si celle-ci en était propriétaire ; que* ***cette question de propriété échappe à la compétence de la juridiction administrative*** » (CE, 6 novembre 1970 Consorts X. contre Commune de La Crau, req. n°76461).
- « *Le talus et la murette servant d'assise à l'avenue Benjamin Dulau situés sur la parcelle 218 P sont nécessaires au soutien d'une voie publique. Ils constituent ainsi une dépendance de ladite voie appartenant au domaine public si toutefois ils sont la propriété de la commune de Cauterets.* ***La question de propriété présentant une difficulté sérieuse, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est prononcé sur la domanialité de cette partie de la parcelle 218 P sans subordonner sa décision au jugement de la question de propriété ainsi posée par l'autorité judiciaire*** » (CE, 29 juin 1990 Consorts Y. contre Commune de Cauterets, req. n° 77011).
- « *Considérant que la société du Camping de la Yole et la société du Domaine de la Yole soutiennent que le chemin des Montilles, classé par la COMMUNE DE VENDRES dans sa voirie communale par une délibération du 18 avril 1994, n'appartient pas à la commune ; que la question de propriété ainsi soulevée pose une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer sur la requête de la COMMUNE DE VENDRES jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de la propriété de ce chemin* » (CE, 9 juillet 2003 Commune de Vendres, req. n°232801).

### B. L'état des personnes (nationalité, filiation, etc.)

**Seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l'état des personnes** (cf. *supra*). Aussi, lorsqu'il est confronté à une question relative, par exemple, à la filiation d'une personne, à sa situation au regard de l'institution du mariage (célibataire, marié, divorcé) ou à sa nationalité, le juge administratif doit poser une question préjudicielle au juge judiciaire :

> « *Le moyen tiré par l'intéressé de ce qu'il aurait perdu la nationalité polonaise par effet d'une loi polonaise et que, par suite, il ne pouvait lui être fait application de la procédure de déclaration de "perte de la qualité de Français" prévue à l'article 96 du Code de la nationalité, pose à juger une* ***question d'état, qui ressortit à la seule compétence de l'autorité judiciaire****. La solution de cette question soulève une difficulté sérieuse* » (CE, Ass. 4 février 1966 Sieur G., req. n°58080, publié au recueil).

C. La validité ou l'interprétation des conventions de droit privé

Le principe (**1**) selon lequel le juge administratif a l'obligation de poser une question préjudicielle au juge civil en cas de question relative à la validité ou l'interprétation d'une convention de droit privé connaît des limites (**2**) et des exceptions (**3**).

7) Le principe de l'obligation pour le juge administratif de poser une question préjudicielle au juge civil

Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III que **seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier la validité ou interpréter une convention de droit privé.**

Par suite, lorsqu'il est confronté à une question ayant trait à la validité ou à l'interprétation d'une convention de droit privé, le juge administratif doit poser une question préjudicielle au juge civil.

Par exemple, tel est le cas lorsqu'il doit statuer :

- Sur la légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension d'un accord collectif de travail, celle-ci étant nécessairement subordonnée à la validité de la convention collective en cause :

  « *Lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur la validité ou l'interprétation d'un accord collectif, le juge administratif, complètement saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel d'extension est, eu égard au caractère de droit privé que présente l'accord, tenu de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de ces questions préjudicielles* » (CE, 21 mai 2008 Société nouvelle de remorquage du Havre, req. n°291115) ?

- Sur la légalité d'une décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé, celle-ci étant subordonnée à la validité de l'accord d'entreprise précisant les conditions d'exercice du droit syndical dans l'entreprise :

  « *Considérant toutefois que pour autoriser le licenciement de M. X… par la société GAN-vie, le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi s'est fondé sur la violation par ce salarié des dispositions d'un accord d'entreprise du 27 juin 1983 concernant l'exercice du droit syndical dans cette entreprise ; que, lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur la validité des stipulations d'un tel accord, la juridiction administrative complètement saisie d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé est tenue, eu égard au caractère de droit privé que présente l'accord d'entreprise, de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle* » *(CE, 29 mai 1992 M. Philippe X, req. n°109749).*

- Sur la légalité d'un arrêté ministériel portant agrément d'un accord ou d'un avenant relatif à l'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi, celle-ci étant nécessairement subordonnée à la validité de l'accord ou de l'avenant en cause :

  « *Considérant que lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur la validité d'un accord ou d'un avenant relatif à l'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi, la juridiction administrative, complètement saisie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel d'agrément est, eu égard au caractère de contrat de droit privé que présente l'accord ou l'avenant, tenue de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle » (CE, 6 octobre 2000 M. Jean-Pierre X, req. n°209312).*

- Sur la légalité d'un décret qui approuve le statut des agents généraux d'assurance négocié et établi par les organisations professionnelles intéressées, celle-ci étant nécessairement subordonnée à la validité de l'accord qui a été négocié :

  « *Considérant que la légalité du décret qui, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 520-2 du Code des assurances, approuve le statut des agents généraux d'assurance négocié et établi par les organisations professionnelles intéressées est nécessairement subordonnée à la validité de l'accord dont s'agit ; que lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur cette validité, le Conseil d'État statuant au contentieux, complètement saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret est, eu égard au caractère de contrat*

*de droit privé que présente l'accord, tenu de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle* » (CE, 27 septembre 1999, req. n°184330).

8) Les limites à l'obligation pour le juge administratif de poser une question préjudicielle au juge civil

Comme indiqué plus avant, la mise en œuvre du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ne doit pas avoir pour effet de violer le droit qu'a tout justiciable d'obtenir que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable.

Pour ce motif, le Conseil d'État a posé des limites à l'obligation pour le juge administratif de poser une question préjudicielle au juge civil dans le cas où serait soulevé un moyen sérieux relatif à la légalité d'une convention de droit privé.

Faisant application des principes dégagés par le Tribunal des conflits dans sa décision SCEA du Chéneau (TC 17 octobre 2011 SCEA du Chéneau, req. n °C 3828, publié au recueil), **le Conseil d'État a posé, dans sa décision « Fédération Sud Santé Sociaux » de 2012** *(CE, Sect. 23 mars 2012 Fédération Sud Santé sociale, req. n°331805)***, deux limites à l'obligation pour le juge administratif de poser une question préjudicielle au juge judiciaire :**

**1) Le juge administratif est dispensé de l'obligation de poser une question préjudicielle, quel que soit le moyen de légalité soulevé contre la convention de droit privé, lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.**

**2) Le juge administratif est également dispensé de l'obligation de poser une question préjudicielle, lorsque le moyen de légalité a trait au défaut de conformité de la convention de droit privé au droit de l'Union européenne. Dans ce cas, le juge administratif « doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union européenne, sans être tenu de saisir au préalable l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'une convention ou d'un accord collectif au droit de l'Union européenne ».**

9) Les exceptions légales à l'obligation pour le juge administratif de poser une question préjudicielle au juge civil : le cas des arrêtés ministériels ou d'agrément des accords collectifs de travail

Le juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté ministériel d'extension ou d'agrément d'un accord collectif, peut statuer directement sur la légalité de l'accord collectif, c'est-à-dire sans avoir à poser de question préjudicielle au juge civil, **lorsque le législateur a prévu que l'entrée en vigueur de cet accord collectif est subordonnée à l'intervention de l'arrêté ministériel d'extension ou d'agrément en cause** *(CE, 28 décembre 2009, req. n°311421 ; solution rappelée par CE, Sect. 23 mars 2012 Fédération Sud Santé Sociaux, req. n°331805).*

## SECTION II : LE REGLEMENT DES CONFLITS DE COMPETENCE PAR LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Le Tribunal des conflits a été créé en 1848 sous la Deuxième République. Il a été ensuite supprimé lors de l'avènement du Second Empire. Il renaîtra sous la Troisième République avec la **loi du 24 mai 1872** relative au Tribunal des conflits.

**La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures** a procédé à une réforme du Tribunal des conflits. **Le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits ainsi qu'aux questions préjudicielles** a complété le dispositif législatif.

Cette réforme a eu des effets sur la composition du Tribunal des conflits (**I**), sur son rôle (**II**) et enfin sur sa procédure (**III**).

## I. La composition du Tribunal des conflits

Nous verrons successivement les membres du Tribunal des conflits (**A**), le Président (**B**) et les rapporteurs publics (**C**).

### A. Les membres du Tribunal des conflits

Le Tribunal des conflits comprend dans sa **formation ordinaire** :

- Quatre conseillers d'État élus par l'Assemblée générale du Conseil d'État,
- Quatre magistrats du siège de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation,
- Deux suppléants dont l'un est élu par l'Assemblée générale du Conseil d'État et l'autre par l'Assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation.

Les membres du Tribunal des conflits sont élus pour 3 ans et sont rééligibles deux fois.

### B. Le Président du Tribunal des conflits

Les membres du Tribunal des conflits choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d'État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.

**Nouveauté importante : le Garde des Sceaux ne préside plus le Tribunal des conflits.**

### C. Les rapporteurs publics

Sont chargés des fonctions de rapporteur public :

- Deux membres du Conseil d'État, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État parmi les rapporteurs publics
- Et deux membres de la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi les membres du parquet général

Ils sont élus pour 3 ans et sont rééligibles deux fois.

**Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.**

## II. Le rôle du Tribunal des conflits

Si le rôle principal du Tribunal des conflits est de régler les conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction (**A**), il peut également, dans deux cas particuliers, intervenir comme juge du fond (**B**).

### A. Le Tribunal des conflits, juge des conflits de compétence

Le Tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction :

- Lorsque le Préfet a élevé le conflit (**1**)
- Lorsqu'une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige (**2**)
- Lorsque les juridictions de l'un et l'autre ordre se sont déclarées respectivement incompétentes pour connaître d'un litige ayant le même objet (**3**)

1) Le conflit positif

L'essentiel des conflits dont connaît le Tribunal des conflits, avant la réforme de 2015, sont des **conflits positifs, par lesquels est revendiquée la compétence de l'ordre juridictionnel administratif, à l'occasion d'une affaire dont est saisie une juridiction judiciaire**.

a) Objet

Lorsque le Préfet estime que la **connaissance d'un litige ou d'une question préjudicielle portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative**, il peut, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.

Le conflit peut être élevé tant que la juridiction de l'ordre judiciaire n'a pas statué sur sa compétence par une décision passée en force de chose jugée.

**Le conflit ne peut pas être élevé en matière pénale.** En matière civile, la Cour de cassation considère qu'il ne peut pas non plus être élevé pour la première fois devant elle *(Cass. 3ème civ., 21 novembre 2024, n°24-10256)*.

b) Procédure

Le Préfet du département dans lequel siège la juridiction saisie adresse au greffe de cette juridiction un « **déclinatoire de compétence** » [21] dans lequel sont présentées les raisons pour lesquelles est déniée la compétence judiciaire. À peine d'irrecevabilité, ce déclinatoire doit être motivé.

Les parties en sont informées par le greffe et sont invitées à faire connaître leurs observations écrites dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du greffe.

Le greffe communique l'affaire au ministère public afin qu'il puisse faire connaître son avis dans le même délai.

Dès réception, le greffe porte cet avis à la connaissance du Préfet et des parties.

La juridiction statue sans délai sur le déclinatoire de compétence : soit elle se déclare incompétente, soit elle rejette le déclinatoire de compétence.

Si la juridiction rend un jugement rejetant le déclinatoire, le préfet peut élever le conflit par arrêté dans les quinze jours suivant la réception du jugement. **L'arrêté de conflit** doit viser le jugement rejetant le déclinatoire et être motivé.

**En cas d'arrêté de conflit, la juridiction doit surseoir à statuer jusqu'à la décision du Tribunal des conflits.**

Le Tribunal des conflits statue sur le conflit positif dans le délai de trois mois à compter de la réception du dossier à son secrétariat. Ce délai peut être prorogé dans la limite de deux mois.

2) La prévention de conflits

La prévention de conflits peut avoir deux objets :

- Éviter un conflit négatif (**a**)
- Régler une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction (**b**)

a) Éviter un conflit négatif

[21] Le Conseil d'État a tranché pour la première fois la question de la nature du déclinatoire de compétence face au refus du préfet de le prendre. Le juge affirme son incompétence en considérant que **la décision de refus n'est pas détachable de la procédure judiciaire à laquelle il se rapporte et qu'une telle décision n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître** *(CE, 20 avril 2005, Régie départementale des transports de l'Ain et autres, req. n°255417).*

**Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal.**

b) Régler une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction

Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.

3) Le conflit négatif

**Lorsque les juridictions de chacun des deux ordres se sont irrévocablement déclarées incompétentes sur la même question, sans que la dernière qui a statué ait renvoyé le litige au Tribunal des conflits, les parties intéressées peuvent le saisir d'une requête aux fins de désignation de la juridiction compétente**.

La requête expose les données de fait et de droit ainsi que l'objet du litige et est accompagnée de la copie des décisions intervenues.

Le recours devant le Tribunal des conflits est introduit dans les **deux mois** à compter du jour où la dernière en date des décisions d'incompétence est devenue irrévocable.

B. Le Tribunal des conflits, juge du fond

Le Tribunal des conflits peut statuer comme juge du fond lorsqu'il est saisi des deux recours spécifiques suivants :

- Le recours en cas de contrariété de décisions au fond (**1**)
- Le recours en responsabilité pour durée excessive des procédures (**2**)

4) Recours en cas de contrariété de décisions au fond

**Le Tribunal des conflits peut être saisi de décisions définitives rendues dans un même litige par l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, lorsqu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice**.

Le Tribunal des conflits a défini ce qu'est un déni de justice au sens de la loi de 1932. Un déni existe « *lorsqu'un demandeur est mis dans l'impossibilité d'obtenir une satisfaction à laquelle il a droit par suite d'appréciations inconciliables portées par les juridictions de chaque ordre soit sur des éléments de fait soit en fonction d'affirmations juridiques contradictoires* » (Trib. des conflits, 14 février 2000, Ratinet).

Le recours devant le Tribunal des conflits est introduit dans les **deux mois** à compter du jour où la dernière en date des décisions statuant au fond est devenue irrévocable.

Le Tribunal des conflits ordonne, s'il y a lieu, les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En présence d'un tel conflit de décisions, **le Tribunal des conflits juge au fond**, à l'égard de toutes les parties en cause.

**Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours**.

5) Le recours en responsabilité pour durée excessive des procédures

Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d'une action en indemnisation du préjudice découlant d'une **durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduite entre les mêmes parties**

**devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables** et, le cas échéant, devant lui.

La partie qui entend obtenir réparation doit **préalablement saisir le garde des Sceaux**, ministre de la Justice, d'une réclamation. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la réclamation vaut décision de rejet. À l'expiration de ce délai, la partie intéressée peut saisir le Tribunal des conflits.

En cas de décision explicite de rejet, la requête doit être présentée dans un délai de **deux mois** à compter du jour de la notification de cette décision. Ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

**Le Tribunal des conflits statue au fond sur la réparation**, après avoir ordonné, s'il y a lieu, les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

## III. La procédure devant le Tribunal des conflits

Nous verrons successivement la saisine du Tribunal des conflits (**A**), la représentation des parties (**B**), le caractère écrit de la procédure (**C**), l'audience publique (**D**), le délibéré (**E**) et la décision rendue (**F**).

### A. La saisine du Tribunal des conflits

Le Tribunal des conflits peut être saisi par :

- Le Préfet en cas de conflit positif,
- Les juridictions en prévention de conflits,
    - Les justiciables en cas de conflit négatif,
    - Conflit de décisions et
    - Recours en responsabilité pour durée excessive des procédures.

Toute personne y ayant intérêt, peut intervenir, à titre accessoire, devant le Tribunal des conflits.

### B. La représentation des parties

Les parties sont représentées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

L'État est dispensé du ministère d'avocat et est représenté par le ministre dont relève l'administration concernée.

### C. Une procédure écrite

La procédure devant le Tribunal des conflits est écrite.

Dès l'enregistrement de l'affaire, le secrétaire invite les parties et le ministre intéressé à présenter leurs observations dans le délai d'un mois. En cas d'élévation de conflit, ce délai est ramené à quinze jours. Ce délai est porté à deux mois en cas de contrariété de décisions au fond et de recours en responsabilité pour durée excessive des procédures.

Ces délais peuvent être réduits par décision du président du Tribunal des conflits en raison de l'urgence.

Les mémoires sont déposées ou adressées au secrétariat qui les notifie aux parties et aux ministres intéressés. Les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, et le ministre intéressé ou le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, peuvent prendre personnellement connaissance des pièces produites au secrétariat du Tribunal des conflits.

Lorsque l'affaire est en état, le président fixe la séance à laquelle elle sera appelée et désigne le rapporteur.

Lorsque l'affaire est inscrite au rôle, les parties et les ministres intéressés en sont avisés cinq jours au moins avant la séance.

Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président. Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.

### D. L'audience publique

Les débats ont lieu en audience publique.

À l'audience publique, le rapporteur expose les données de l'affaire ainsi que la position des parties et des ministres intéressés, sans faire connaître son avis.

Après le rapport, les avocats représentant les parties peuvent présenter des observations orales.

Le rapporteur public est ensuite entendu dans ses conclusions.

Les avocats peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.

### E. Le délibéré

Le délibéré des juges est secret.

En principe, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.

En cas de partage égal des voix, le président réunit le Tribunal des conflits dans la même formation qui procède à une nouvelle délibération à la prochaine séance.

Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n'ont pu se départager, l'affaire est examinée en **formation élargie**.

### F. La décision rendue

Nous verrons la forme de la décision (**1**), le fait qu'elle est en principe insusceptible de recours (**2**) et enfin sa portée (**3**).

#### 1) La forme de la décision

Si le Tribunal des conflits rend normalement des décisions (**a**), il peut aussi, dans certains cas particuliers, rendre des ordonnances (**b**).

##### a) Une décision rendue après audience publique

Le Tribunal des conflits rend des « décisions » au nom du peuple français, qui sont motivées et lues en audience publique.

##### b) Une ordonnance pouvant être rendue sans audience publique

Sans audience publique, le président du Tribunal des conflits peut, par ordonnance prise conjointement avec le membre du tribunal le plus ancien appartenant à l'autre ordre de juridiction :

- Donner acte des désistements
- Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une affaire
- Rejeter les requêtes manifestement irrecevables
- Corriger les erreurs purement matérielles affectant les décisions rendues

- Et enfin, depuis la réforme de 2015, **régler les questions de compétence dont la solution s'impose avec évidence.**

### 2) Une décision en principe insusceptible de recours

Les décisions du Tribunal des conflits ne peuvent faire l'objet ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation.

Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'une tierce opposition, sauf lorsque le tribunal statue au fond.

Elles peuvent seulement faire l'objet d'un recours en interprétation et en rectification.

### 3) Portée des décisions du Tribunal des conflits

**Les décisions du Tribunal des conflits s'imposent à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif**.

Elles bénéficient d'une **totale autorité de chose jugée s'attachant tant au motif qu'au dispositif de la décision** *(CE, 6 février 1987, Époux Babin, req. n°64509).*

# TITRE III : LES GARANTIES STATUTAIRES DE L'EXERCICE DES POUVOIRS JURIDICTIONNELS

Si les juges judiciaires ont assez tôt bénéficié de garanties statutaires destinées à assurer leur indépendance vis-à-vis de l'Etat (**CHAPITRE 1**), la relation étroite qui unit l'administration à la justice administrative a retardé la mise en place de ces garanties, au point que ce n'est qu'à l'occasion de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 que sera consacré constitutionnellement le statut de la juridiction administrative – même si le Conseil constitutionnel était intervenu avant cette date pour combler ce vide juridique (**CHAPITRE 2**).

## CHAPITRE 1 : LES GARANTIES STATUTAIRES DES JUGES JUDICIAIRES

La situation des juges judiciaires est ambivalente : chargés d'assurer une mission de service public, et nommés à leurs fonctions par décret du Président de la République, ils ne peuvent rendre la justice que s'ils présentent des garanties suffisantes d'indépendance à l'égard des tiers, particulièrement ceux qui pourraient exercer sur eux des pressions en influant sur leur carrière. C'est pourquoi, même s'ils sont, *in fine*, des agents publics travaillant pour le compte de l'Etat, il est impossible de les rattacher au statut de la fonction publique d'Etat : les juges judiciaires bénéficient en France d'un statut *ad hoc*, fixé pour l'essentiel par l'article 64 de la Constitution et l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 *(la loi « organique » visée à l'article 64 C., dont les dispositions ont évidemment été modifiées à de nombreuses reprises depuis, mais dont les modifications sont, en vertu de l'assise constitutionnelle du statut des magistrats judiciaires, sujettes au contrôle de leur constitutionnalité).*

*Art. 64 C. : « Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.*
*Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.*
*Une loi organique porte statut des magistrats.*
*Les magistrats du siège sont inamovibles ».*

Bien que tous les magistrats de l'ordre judiciaire appartiennent au même corps et soient donc soumis au même statut, leur indépendance et leur protection n'est pas tout à fait identique en raison de la division des fonctions, au sein de la magistrature, en deux grandes catégories (même si, au cours d'une carrière, les magistrats judiciaires peuvent exercer successivement l'une et l'autre fonction).

- D'un côté, il y a les magistrats chargés de trancher les litiges, de « dire le droit », bref, de rendre des décisions de justice et qui doivent en conséquence bénéficier des garanties d'indépendance les plus fortes. Parce que, dans une salle d'audience, ces magistrats exercent leurs fonctions assis, on les désigne par les termes « **magistrats du siège** » ou « magistrature assise ».
- De l'autre côté, il y a les magistrats chargés de représenter la collectivité, de défendre l'intérêt général, de requérir la justice et dont les fonctions impliquent donc un lien étroit avec les décisions politiques prises par le gouvernement. Plusieurs termes servent à les désigner, selon que l'accent est mis sur le fait qu'ils exercent leurs fonctions debout (« magistrature debout »), qu'ils servent l'intérêt public (« **Ministère public** »), ou qu'au Moyen-Age ils exerçaient leurs fonctions parqués dans un espace délimité sur trois côtés par les juges et sur le dernier par la barre des témoins (ce petit parc de justice étant dénommé « **Parquet** »).

Il faudra donc présenter d'abord les garanties statutaires dont bénéficient les magistrats du siège (**SECTION 1**) avant d'étudier les règles dérogatoires applicables aux magistrats du parquet (**SECTION 2**).

## SECTION 1 : LA PROTECTION STATUTAIRE MAXIMALE DES MAGISTRATS DU SIEGE

Pour pouvoir exercer leurs fonctions de façon satisfaisante, pour pouvoir se comporter en « digne et loyal magistrat », ainsi que le prévoit leur serment, les juges doivent bénéficier de garanties relatives à leur inamovibilité (I.), avancement (II.) et discipline (III.).

### I. L'inamovibilité des magistrats du siège

Le **gouvernement** ne peut prendre **aucune sanction individuelle** contre un magistrat (révocation, suspension, déplacement, mise à la retraite). C'est une garantie de valeur constitutionnelle (art. 64 C.).

En revanche, il n'est pas interdit d'imposer une **rotation** au sein des juridictions, en limitant la durée d'exercice d'une fonctions particulière (président d'une juridiction, juge d'instruction, juge des enfants, etc.). A l'expiration de ce délai, soit le magistrat veut continuer à exercer les mêmes fonctions et il doit alors changer de juridiction, soit il veut rester dans la même juridiction et il doit alors changer de fonctions.

### II. L'avancement des magistrats du siège

On appelle « grade » la position du magistrat dans la hiérarchie (historiquement, le second grade était le moins élevé, le rang suivant était le premier grade, et « hors hiérarchie » était le grade le plus élevé ; avec l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, l'ordre et la terminologie sont modifiées, à compter du 31 décembre 2025 : les magistrats « hors hiérarchie » deviennent magistrats du 3ème grade, le rang le moins élevé devient le 1er grade.

- le grade détermine notamment le montant de sa rémunération. Chaque grade est plus précisément composé d'échelons.
- mais plusieurs fonctions sont également liées au grade : par ex., on ne peut pas être juge des enfants, président de tribunal judiciaire, ou conseiller de cour d'appel si l'on n'est pas magistrat de deuxième grade. De même, seul un magistrat de troisième grade peut être premier président de cour d'appel ou

conseiller à la Cour de cassation, ou même président de certains tribunaux judiciaires particulièrement importants (Paris, Aix-en-Provence…).

La question de l'avancement est importante : si un magistrat craint pour sa carrière, il risque d'être moins libre dans la prise de décision ; inversement, si tous les magistrats progressent dans la carrière judiciaire de la même façon, cela n'incite pas à être performant (les bons comme les mauvais sont promus de façon identique). C'est pourquoi la carrière des magistrats est déterminée à la fois par un critère d'ancienneté et un critère de choix.

- Pour **passer du premier au deuxième grade**, il faut d'abord 7 ans d'ancienneté. Il faut ensuite être inscrit à ce que l'on appelle un « tableau d'avancement ».
    - ce tableau est établi par une commission d'avancement composée de magistrats d'ancienneté diversifiée, sur la base d'une évaluation de l'activité professionnelle de chaque magistrat établie par ses supérieurs hiérarchiques directs et par le 1er président de la CA du ressort dans laquelle il exerce ses fonctions.
    - il est ensuite communiqué à chaque magistrat y figurant, au conseil supérieur de la magistrature, et affiché au siège de chaque juridiction. Il est alors possible à tout magistrat ne figurant pas sur la liste de former un recours auprès de la commission pour demander son inscription au tableau.
    - mais ce n'est parce qu'un magistrat figure sur le tableau d'avancement qu'il va forcément changer de grade : **il faut d'abord que le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) donne un avis conforme**, puis que le ministre de la Justice propose le nom au président de la République, et enfin que celui-ci signe le décret d'avancement de grade.
- Pour passer du deuxième grade au troisième, les règles sont différentes :
    - D'abord, il faut obligatoirement passer par une période dite de « mobilité statutaire », c'est-à-dire exercer des fonctions auprès d'une administration, d'une entreprise assurant des missions d'intérêt général, ou auprès d'institutions européennes ou internationales. L'idée est de familiariser les magistrats appelés à exercer des fonctions importantes avec des activités extrajudiciaires de la vie quotidienne
    - Ensuite, il y a deux possibilités :
        - ❖ Par défaut, comme pour le passage du premier au deuxième grade, par le biais d'un tableau d'avancement sur lequel les magistrats susceptibles d'être promus sont inscrits par une commission d'avancement. Le tableau est ensuite soumis au CSM, au ministre de la Justice puis au président de la République pour que soient pris (ou non) les décrets de nomination correspondants.
        - ❖ S'il s'agit d'exercer les fonctions de président ou de procureur d'un TJ, de premier président d'une CA, ou de conseiller/avocat général près la Cour de cassation, pas de tableau d'avancement : c'est une formation du CSM qui décide de l'aptitude du magistrat concerné à exercer ces fonctions, selon des critères posés par l'art. 10-3 nouveau de l'ordonnance de 1958 et l'article 15 al. 2 nouveau de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. Le CSM propose ensuite les candidatures retenues à ces fonctions au président de la République, pour nomination.

Par ailleurs, la loi organique renforce la professionnalisation de la hiérarchie judiciaire en introduisant une évaluation élargie des chefs de cour d'appel et de tribunal, sans préjudice, pour ces derniers, de l'évaluation hiérarchique. Cette évaluation· élargie est confiée à une instance collégiale (art. 12-1-1 nouveau de l'ordonnance de 1958), qui devra apprécier leurs aptitudes à l'administration et à la gestion (selon un nombre de critères variables en fonction du poste et fixés par le nouvel art. 10-3 de l'ordonnance), après sollicitation de l'ensemble de l'environnement professionnel du magistrat évalué. Cette instance ne pourra porter aucune appréciation sur l'exercice des fonctions juridictionnelles afin de garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire. Les autorités de nomination disposeront ainsi d'éléments objectifs quant aux qualités professionnelles de ces magistrats. Cette évolution vise à renforcer la qualité de la gouvernance et du pilotage des juridictions

### III. La discipline des magistrats du siège

Comment sanctionne-t-on une faute disciplinaire ? Il faut d'abord la définir avant de déterminer ses sanctions.

La **faute disciplinaire** est définie par la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 comme « *tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état* ».

Il s'agit donc d'un manquement aux obligations professionnelles :

- **Dans l'exercice de la fonction de juger**, mais alors ce n'est pas simplement une erreur de jugement du juge. Il faut une atteinte grave aux droits fondamentaux des parties (détention injustifiée par exemple, en matière pénale) ; ou une faute susceptible d'entraîner la condamnation de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice *(cf. infra)*, par exemple perte d'un dossier ou de pièces, ou simplement négligence, entraînant un allongement excessif du délai de traitement de la procédure ; ou une violation grave des obligations découlant du serment prêté (par ex., violation du secret des délibérations).
- **Dans le cadre de la vie privée du juge**, lorsque la faute commise jette le discrédit sur sa fonction de juge (manquement à l'honneur, la délicatesse, la dignité : ivresse, vie dissolue, *a fortiori* infractions pénales).

Les **sanctions encourues** en cas de faute disciplinaire sont :

- Le blâme inscrit au dossier
- Le déplacement d'office (mutation forcée)
- Le retrait de certaines fonctions, ou bien l'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique (interdiction professionnelle)
- L'abaissement d'échelon
- L'exclusion temporaire des fonctions avec privation du traitement
- La rétrogradation
- La mise à la retraite d'office
- La révocation

Les garanties statutaires sont liées à la **procédure disciplinaire** :

- Les poursuites sont exercées devant le **Conseil Supérieur de la Magistrature**, qui joue le rôle de conseil de discipline. Créé initialement par une loi de 1883, il s'agissait alors simplement d'une formation de la Cour de cassation. Depuis une loi constitutionnelle de 1993, c'est une instance autonome composée de 15 membres : 7 magistrats (dont le président, qui est le 1er président de la Cour de cassation), un avocat, un membre du Conseil d'Etat et 6 personnalités extérieures désignées par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
- **Le Conseil peut être saisi** (donc les poursuites disciplinaires initiées) par le **ministre de la Justice** ou le **premier président de la CA** dont dépend le juge poursuivi, ou (depuis 2008), par tout **justiciable « qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge dans l'exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité est susceptible de revêtir une qualification disciplinaire ».**
- Le magistrat poursuivi peut se défendre seul ou avec l'assistance d'un avocat ou d'un autre magistrat.
- **La décision prise par le CSM est souveraine** : elle s'impose au ministre de la Justice, chargé de l'exécuter sans pouvoir l'alléger ou l'alourdir.
- Un recours est possible, devant le Conseil d'Etat.

## SECTION 2 : LA PROTECTION STATUTAIRE ATTENUEE DES MAGISTRATS DU PARQUET

Si les membres du Ministère public sont recrutés et nommés de la même façon que leurs homologues du siège, leur carrière et l'exercice de leurs fonctions présentent des spécificités notables, en raison de leur

subordination hiérarchique au gouvernement, par le biais du ministre de la Justice. On se contentera d'insister ici sur ces spécificités.

S'agissant du **Conseil Supérieur de la Magistrature** :

- Sa **composition**, lorsqu'il est amené à se prononcer sur la carrière des procureurs, est différente : la présidence est assurée par le procureur général près la Cour de cassation ; il y a ensuite 5 magistrats du parquet et un magistrat du siège ; puis l'on retrouve les mêmes personnes que pour la formation compétente à l'égard des magistrats du siège (un avocat, un conseiller d'Etat, 6 personnalités extérieures).
- Son **rôle dans leur nomination** est moindre : le CSM donne un **avis simple** au ministre de la Justice pour les postes de procureurs de la République, et au conseil des ministres pour les procureurs généraux. Et il n'a aucun pouvoir de proposition : l'initiative de la nomination appartient exclusivement à l'Exécutif.
- En ce qui concerne **la procédure de sanction**, le Conseil est saisi par le ministre de la Justice ou le procureur général CA dont dépend le magistrat du parquet poursuivi, ou tout justiciable « qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du parquet dans l'exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité est susceptible de revêtir une qualification disciplinaire ». Surtout, la sanction est décidée par le ministre de la Justice, après avis simplement consultatif du CSM. Ce dernier n'est donc pas ici une juridiction disciplinaire mais seulement une autorité morale. La décision du ministre peut toutefois être contestée devant le conseil d'Etat par le biais d'un recours en excès de pouvoir.

**S'agissant du statut des procureurs**, l'article 5 de l'ordonnance statutaire les soumet à un **principe hiérarchique** inconcevable pour un magistrat du siège, et qui lie les procureurs entre eux en fonction de leur grade, ainsi qu'au ministre de la Justice : *« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre ».*

- Cela implique en premier lieu que les magistrats du Parquet ne sont **pas inamovibles**. Ils peuvent être déplacés d'un poste à un autre au gré des besoins de leur service ; une mutation disciplinaire serait néanmoins soumise au respect préalable de la procédure disciplinaire.
- Cela implique ensuite que les magistrats du Parquet ne sont **pas indépendants vis-à-vis de l'Exécutif dans l'exercice de leurs missions.**
    - **D'abord**, si le Conseil constitutionnel a considéré que l'indépendance des magistrats du parquet était assurée par l'article 64 de la Constitution faisant du président de la République le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, cette indépendance doit, selon le Conseil, se concilier avec l'article 20 de la Constitution, selon lequel *« le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation »* (*Cons. const., 8 décembre 2017, n° 2017-680 QPC*). Ainsi, l'article 30 du Code de procédure pénale confie au ministre de la Justice la conduite de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, qui veille également à la cohérence de son application sur le territoire de la République. Pour remplir cette fonction, le ministre de la Justice adresse aux parquetiers des instructions générales ; il lui est en revanche interdit de leur adresser des instructions dans des affaires individuelles (art. 30, al.3 CPP).
    - **Ensuite**, le procureur général près la cour d'appel veille quant à lui à l'application de la loi pénale sur son ressort et au bon fonctionnement des parquets (art. 35, al.1 CPP). Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, adapte au contexte propre à son ressort les instructions générales du ministre et procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République (art. 35, al.2 CPP)[22], ces derniers devant lui adresser des rapports sur l'application de ces consignes dans leur parquet et la gestion de ce dernier (art. 39-1 al. 2 CPP). L'article 36 du Code de procédure pénale lui donne la possibilité d'*« enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure,*

[22] En mai 2020, une substitut du procureur de la République de Limoges a reçu un avertissement disciplinaire du procureur général de la cour d'appel de Limoges pour avoir « adopté des initiatives personnelles dans la réquisition des peines contraires aux orientations de politique pénale définies par le procureur de la République, conduisant à des incohérences dans l'action du Parquet, sans concertation avec ses collègues et sa hiérarchie ».

*d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes ».*

- **Enfin**, l'article 44 du Code de procédure pénale donne quant à lui autorité au procureur de la République sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police.
- **Cependant**, **cette subordination hiérarchique connaît deux limites**. En premier lieu, si un procureur ou un procureur général va à l'encontre des instructions qu'il reçoit, il s'expose à une sanction disciplinaire, mais son supérieur ne pourra se substituer à lui pour mettre l'instruction en application, de sorte que la désobéissance d'un magistrat du Parquet peut efficacement faire obstacle à la mise en œuvre d'une politique publique. En second lieu, l'adage selon lequel *« la plume est serve, mais la parole est libre »* permet à tout procureur de la République, sans risque de sanction, de prendre à l'oral des réquisitions contraires aux réquisitions écrites prises sur ordre du procureur général. L'article 33 CPP a retranscrit cet adage dans la loi : le représentant du ministère public *« est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données »,* mais *« il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice ».*

## CHAPITRE 2 : LES GARANTIES STATUTAIRES DES JUGES ADMINISTRATIFS

Pour des raisons historiques déjà évoquées, les juges administratifs ne dépendent pas de l'ordonnance statutaire de 1958, ni de l'article 64 de la Constitution, dont les garanties ne peuvent donc leur être appliquées, mais de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative au statut général des fonctionnaires, ainsi que de dispositions diverses (en particulier le code de justice administrative).

Ils sont donc considérés avant tout comme des agents de l'Etat, ce qui explique que, contrairement à leurs homologues judiciaires, les juges administratifs ne sont pas formés à l'école nationale de la magistrature (ENM), mais jusqu'au 31 décembre 2021, à l'école nationale de l'administration (ENA) et, depuis le 1er janvier 2022, à l'institut national du service public (INSP, qui remplace l'ENA). Or, il s'agit d'une institution chargée d'assurer la formation de l'ensemble des hauts fonctionnaires d'Etat, et pas seulement des magistrats administratifs ; d'ailleurs, les élèves-fonctionnaires de cette école n'ont aucune garantie d'exercer à l'issu de leur formation des fonctions de magistrat administratif : c'est leur rang de sortie qui déterminera le poste qu'ils occuperont dans la fonction publique, magistrat inclus.

En outre, alors que les juges du siège judiciaires composent un corps unique, les juges du siège administratifs se répartissent en **4 corps**, chacun ayant un statut propre : les magistrats de la Cour des comptes, les magistrats des chambres régionales des comptes, les membres du Conseil d'Etat et les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. A cet égard, on observera pendant longtemps seuls les magistrats des juridictions financières étaient expressément qualifiés de « magistrats » : il a fallu attendre une loi de 2012 pour que ce terme serve également à désigner les juges des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et cette dénomination est toujours refusée aux membres du conseil d'Etat.

Selon la même logique, seuls les magistrats des juridictions financières se voient expressément garantir **l'inamovibilité**, par le code des juridictions financières (art. L. 120-1 CJF pour la Cour des comptes et art. L. 220-1 CJF pour les chambres régionales des comptes). Toutefois, l'article L. 231-3 CJA, même s'il s'abstient de nommer expressément le principe, en pose la teneur au profit des juges administratifs des tribunaux et cours d'appel, en s'inspirant clairement de la formulation adoptée pour les juges judiciaires : *« Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en*

*avancement. »* Paradoxalement, ce sont donc là encore les membres du Conseil d'Etat qui sont les moins bien lotis, faute de tout texte garantissant leur inamovibilité, même de façon implicite[23].

Enfin, **l'indépendance** des juges administratifs a été renforcée progressivement, bien qu'elle reste moins garantie que celle des juges judiciaires.

- D'abord, le code de justice administrative et le code des juridictions financières prévoient que l'avancement et la sanction des juges administratifs font l'objet d'avis (pour l'avancement) et de décisions (pour la sanction) rendus par des organismes jouant un rôle similaire à celui du CSM à l'égard les juges judiciaires. Il s'agit du Conseil supérieur de la Cour des comptes, du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, de la Commission supérieure du Conseil d'Etat et du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
- Ensuite, l'indépendance de la juridiction administrative et la spécificité de ses fonctions se sont vues reconnaître une valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa *décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980 « loi portant validation d'actes administratifs ».* Avec cette décision, pour la première fois, le juge administratif « s'ancre » dans le bloc de constitutionnalité : la suppression du dualisme juridictionnel devient impossible à partir de cette date sans une révision constitutionnelle[24]. **Le Conseil constitutionnel estime** en effet **qu'un principe fondamental reconnu par les lois de la République** (ci-après, « PFRLR ») **protège l'indépendance des juridictions administratives contre les atteintes du législateur et de l'exécutif**. Pour consacrer l'indépendance de la juridiction administrative et la spécificité de ses fonctions, **le Conseil constitutionnel se fonde sur la loi du 24 mai 1872 qui**, pour rappel, **accorde définitivement au Conseil d'État la justice déléguée** :

  *« 6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire* ***et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le gouvernement*** *; qu'ainsi, il n'appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ».*

# PARTIE II : LA HIERARCHISATION DES JURIDICTIONS AU SEIN DE CHAQUE ORDRE JURIDICTIONNEL

Dans l'ordre administratif comme dans l'ordre judiciaire, une structure pyramidale relie les tribunaux, cours d'appels et juridictions de cassation (Conseil d'Etat et Cour de cassation), considérées comme des juridictions « ordinaires » (**TITRE I**). Certaines juridictions rendent des décisions qui s'imposent aux précédentes, sans pour autant qu'elles soient considérées comme faisant partie intégrante de cette hiérarchie (**TITRE II**).

## TITRE I – L'ORGANISATION PYRAMIDALE DES JURIDICTIONS ORDINAIRES

Bien que chaque juge reste fondamentalement libre des décisions qu'il prend à l'occasion du litige qui lui est soumis, il est de tradition en France que le plaideur insatisfait de la décision puisse la contester devant une autre juridiction de même nature. On parle à cet égard de « voie de recours », et le mécanisme trouve son origine à l'époque où le roi, pour asseoir son autorité sur les seigneurs, lesquels rendaient la justice dans leur

[23] S'il est vrai qu'une règle coutumière dissuade le plus souvent l'Exécutif de révoquer des membres du conseil d'Etat, il est possible de citer au moins un exemple d'une telle révocation : l'affaire Jacomet (1960), le conseiller du même nom ayant été révoqué pour les propos critiques qu'il avait tenus à l'égard du gouvernement lorsqu'il était détaché dans les fonctions de secrétaire général de l'administration en Algérie.

[24] On rappellera qu'avant cette décision, l'existence du juge administratif n'était que législative, la Constitution du 4 octobre 1958 ne visant à l'origine du Conseil d'État que dans sa fonction consultative. Or, ce qu'une loi a fait, l'autre peut le défaire. Dès lors, il suffisait avant la décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980 que le législateur intervienne à travers l'adoption d'une loi ordinaire pour supprimer le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire et, avec lui, le dualisme juridictionnel. Le juge judiciaire étant, au contraire, dès l'origine « ancré » dans le bloc de constitutionnalité grâce à la DDHC et à la Constitution de 1958 (art. 66 C), c'est le juge administratif qui aurait disparu du système en cas d'abrogation des dispositions légales l'instituant par une nouvelle loi (ordinaire).

seigneurie, permettait aux justiciables insatisfaits de la décision rendus par lesdits seigneurs de s'adresser *in fine* à lui pour obtenir justice (à l'issue de plusieurs étapes qui constituaient des voies de recours intermédiaires). Le roi faisait donc office de dernière juridiction à pouvoir statuer sur un litige, et sa décision était définitive et l'emportait sur toutes les décisions précédentes, manifestant ainsi la suprématie du pouvoir royal sur le pouvoir seigneurial.

Si de nos jours, la dimension politique a disparu, le principe que la décision rendue par juridiction peut être contestée en saisissant une juridiction hiérarchiquement supérieure demeure, aussi bien dans l'ordre judiciaire que dans l'ordre administratif. L'objectif est désormais d'assurer une meilleure justice, et ce d'autant plus que les magistrats des juridictions dites « de premier degré » (le plus souvent dénommées « tribunaux », dont les quatre principaux sont au nombre de 786) occupent, au sein de leur corps, le rang le moins élevé, tandis que les magistrats des juridictions de recours, dites « juridictions du second degré » (le plus souvent dénommées « cours d'appel », il y en a 36 au total), ont un grade supérieur, gage d'une plus grande expertise et donc, en théorie, d'une moindre faillibilité.

On observera que, si les magistrats des juridictions de recours peuvent défaire les décisions des juridictions inférieures, et s'ils sont le plus souvent chargés d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats composant ses juridictions inférieures (c'est-à-dire de les noter), ils ne peuvent en revanche pas utiliser leur position hiérarchique pour ordonner aux juges de premier degré de prendre telle ou telle décision (seule la hiérarchie au sein du ministère public implique ce type de subordination, mais les procureurs ne sont pas des « juges » au sens strict du terme).

La possibilité de former un recours contre une décision de justice ne s'arrête pas aux cours d'appel : il est encore possible d'aller au-delà, et de saisir une juridiction de rang encore supérieur, unique au sommet de son ordre juridictionnel. Dans l'ordre judiciaire, il s'agit de la Cour de cassation et, dans l'ordre administratif, du Conseil d'Etat. Ces juridictions sont saisies par le biais d'un recours que l'on dénomme « pourvoi en cassation » et qui présente plusieurs spécificités par rapport à un appel, lesquelles seront étudiées dans les fascicules consacrés respectivement à la justice civile et à la justice administrative.

## TITRE II – LE ROLE FONDAMENTAL DE CERTAINES JURIDICTIONS HORS HIERARCHIE

Il existe des juridictions dont les décisions ont vocation à s'imposer, en raison de la place dans la hiérarchie des normes des dispositions dont elles assurent le respect, aux tribunaux, cours d'appel, et juges de cassation.

Pour autant, il n'est pas possible de considérer que la saisine de ces juridictions constitue une voie de recours, dans la mesure où la décision qu'elle sont amenées à rendre n'a pas vocation à remettre directement en cause la décision d'une juridiction inférieure. En raison de leurs particularités, ces juridictions ne s'intègrent pas dans la dualité des ordres juridictionnels mais occupent une place *sui generis*, et l'importance pratique de leur jurisprudence en tant que source de droit implique qu'on leur consacre des développements spécifiques.

Il s'agit, d'une part, d'une juridiction nationale dénommée Conseil constitutionnel (**CHAPITRE 1**) et, d'autre part, de deux juridictions internationales dotées d'une influence géographique étendue, la Cour européenne des droits de l'homme (**CHAPITRE 2**) et la Cour de justice de l'Union européenne (**CHAPITRE 3**).

# CHAPITRE 1 : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Institué en 1958 par la Constitution de la cinquième République, le Conseil constitutionnel est une juridiction dont la fonction principale est de contrôler la conformité des lois à la Constitution (art. 61 et 61-1 C.)[25]. A mi-chemin entre une juridiction et un organe politique, il n'est pas composé de magistrats, mais de neufs membres, dénommés « sages », dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable (art. 56 C.). Trois de ces membres sont désignés par le président de la République, qui en profite pour désigner l'un d'eux comme président du Conseil ; trois autres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et les trois derniers par le président du Sénat. Sont également membres de droit à vie du Conseil constitutionnel les anciens présidents de la République.

Le Conseil constitutionnel peut être amené à contrôler la constitutionnalité d'une loi, soit avant l'entrée en vigueur de celle-ci – c'est le contrôle « *a priori* » de la loi (**SECTION 1**), soit après l'entrée en vigueur de celle-ci – c'est le contrôle « *a posteriori* » de la loi (**SECTION 2**).

## SECTION 1 : LA SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL A PRIORI

Pour qu'une loi votée par le Parlement entre en vigueur, il faut qu'elle soit promulguée par le Président de la République (art. 10 C.), puis publiée (art. 1 C. civ.).

Le Conseil constitutionnel ne peut se saisir d'office du contrôle de constitutionnalité de la loi. Si certaines lois particulièrement importantes pour le fonctionnement des institutions lui sont obligatoirement soumises avant leur promulgation, pour **la plupart des lois** votées par le Parlement, la saisine du Conseil constitutionnel est **facultative**, et **ne peut** alors **être effectuée que par** les personnes visées à l'article 61 C. :

- Le président de la République
- Le premier Ministre
- Le président de l'Assemblée nationale
- Le président du Sénat
- 60 députés
- 60 sénateurs

Saisi *a priori*, le Conseil statue dans le délai d'un mois, ramené à huit jours en cas d'urgence. S'il juge la loi conforme à la Constitution (quitte à l'assortir de réserves d'interprétation ou moduler ses effets dans le temps), son processus d'entrée en vigueur suit son cours. **S'il juge la loi contraire à la Constitution, sa promulgation devient impossible** (art. 62 C.), à charge pour le Parlement d'en revoir les dispositions jugées incompatibles avec la Constitution. Aucun recours n'est possible contre la décision du Conseil constitutionnel.

## SECTION 2 : LA SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL A POSTERIORI

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un article 61-1 :

> « *Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé*.
>
> *Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article* ».

[25] De façon plus marginale, il est également chargé de contrôler la régularité de l'élection du président de la République (art. 58 C.) ainsi que celle des députés et sénateurs (art. 59 C.). Il veille également à la régularité des référendum (art. 60 C.).

La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a par la suite précisé les modalités d'application de la nouvelle procédure.

A l'analyse, il apparaît que la « **question prioritaire de constitutionnalité** » (QPC) n'est pas un recours contentieux à proprement parler, mais un « **incident de procédure » permettant, à l'occasion d'un litige, de contrôler la constitutionnalité *a posteriori* d'une loi susceptible d'être appliquée par la juridiction saisie de ce litige**. Le formalisme de la QPC répond pour cette raison à des conditions très particulières **(I).** Placés au cœur du mécanisme, le Conseil d'État et la Cour de cassation ont vu leurs rôles respectifs au regard des règles constitutionnelles redéfinis **(II).**

## I. La QPC, un contrôle de constitutionnalité *a posteriori* d'une loi

Il faut bien comprendre que **c'est à l'occasion d'une action en justice devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif[26] qu'un justiciable peut soulever devant le juge saisi de cette action le moyen tiré de ce qu'une « disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit »**.

- Autrement dit, il n'existe pas de recours en inconstitutionnalité *ad hoc*, comme il existe un recours devant les juridictions administratives pour contester la conformité d'un acte administratif aux normes qui lui sont supérieures : **une demande formée devant une juridiction administrative ou judiciaire et visant à l'abrogation d'une disposition législative inconstitutionnelle en dehors de tout litige serait irrecevable.**
- En revanche, **cette juridiction ne peut elle-même se prononcer sur la conformité à la Constitution de la loi contestée. Ce rôle revient exclusivement au Conseil constitutionnel**, de sorte que le juge ordinaire se contente de déterminer si le moyen critiquant la constitutionnalité de la loi mérite ou non d'être transmis au Conseil. De ce point de vue, **le juge ordinaire joue un rôle de « filtre » des QPC**.
- On observera que **la question est « prioritaire »** : cela signifie que, dès lors que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité est formé, l'examen de sa transmissibilité au Conseil constitutionnel prend le pas sur le jugement du litige. La règle est logique, puisque par hypothèse, la conformité ou contrariété de la loi contestée à la Constitution est de nature à impacter l'issue du litige.

Les **conditions de recevabilité** d'une QPC sont identiques en première instance, en appel ou en cassation, quel que soit l'ordre auquel appartient la juridiction saisie du litige (dès lors du moins que la question est soulevée pour la première fois devant cette juridiction). On en présentera d'abord les conditions de forme (A) puis les conditions de fond (B), puis l'on dira quelques mots des effets de la décision rendue en réponse à la QPC (C).

### A. Les conditions de forme de la QPC

D'abord, « pour exercer le droit qui lui est reconnu par l'article 61-1 de la Constitution, toute partie à une instance doit, devant la juridiction saisie, spécialement désigner, dans un écrit distinct et motivé, d'une part, (…) les dispositions législatives qu'elle estime applicables au litige ou à la procédure et dont elle soulève l'inconstitutionnalité et, d'autre part, ceux des droits ou libertés que la Constitution garantit auxquels ces dispositions porteraient atteinte » *(Cons. const., 26 juill. 2013, n° 2013-334/335 QPC).* La présentation d'un écrit distinct permet de ne pas retarder l'instruction de l'affaire en permettant un traitement rapide et « prioritaire » de la QPC et de bien distinguer matériellement ce qui relève du juge ordinaire et de ce qui relève du Conseil constitutionnel.

[26] Ce qui implique qu'une QPC ne peut pas être soulevée devant le Tribunal des conflits : « *considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1607 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, issu de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être présentée que devant les juridictions qui relèvent du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ; que dès lors, une telle question ne peut être présentée devant le Tribunal des conflits ; qu'ainsi la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A est en tout état de cause irrecevable* » (T. confl., 4 juillet 2011, Jacques Bidalou c/min. Budget, req. n°C 3803).

Ensuite, le sort de la QPC est tributaire de l'examen du fond du litige par la juridiction qui en est saisie. Ainsi, la QPC sera irrecevable chaque fois que l'action au fond ne pourra être jugée pour cause de désistement, d'incompétence, de non-lieu à statuer ou d'irrecevabilité.

Par ailleurs, l'exception d'inconstitutionnalité de la loi ne peut pas être relevée d'office par le juge, mais doit être invoquée par une partie. En revanche, le moyen peut être soulevé pour la première fois en première instance, en appel ou en cassation, en principe lors de la phase d'instruction de l'affaire. Une exception notable est toutefois apportée par l'article 23-1 de la loi organique en matière criminelle, dans la mesure où le moyen ne peut pas être soulevée pour la première fois devant une Cour d'assises statuant en premier ressort, mais au plus tôt à l'occasion d'un appel devant une Cour d'assises d'appel.

### B. Les conditions de fond de la QPC

En premier lieu, le juge saisi du litige doit s'assurer que **la QPC a bien pour objet de contester une disposition de nature législative**, et non une autre norme.

- D'un point de vue organique, ceci inclus toutes les dispositions ayant valeur législative, quel que soit leur auteur : dispositions figurant dans les lois ordinaires, les ordonnances ratifiées des articles 38 et 74-1 de la Constitution, les actes pris dans des matières législatives par le président de la République au titre de l'article 16 de la Constitution. Soulignons, à ce titre, que tant qu'elles n'ont pas subi la procédure de « délégalisation » prévue à l'article 37 alinéa 2 de la Constitution, les dispositions réglementaires contenues dans une loi constituent des « textes de forme législative » susceptibles de faire l'objet d'une QPC
- De façon plus surprenante, le Conseil constitutionnel a admis que, compte tenu des objectifs assignés à la procédure de l'article 61-1 de la Constitution, une QPC puisse porter sur une disposition législative abrogée, dès lors qu'elle est applicable au litige[27].
- En revanche, certaines dispositions sont donc *de facto* exclues du champ d'application de la QPC, telles que les lois constitutionnelles ; les lois adoptées par référendum *(Cons. const., 25 avril 2014, n° 2014-392 QPC)* ; les dispositions d'une loi ayant pour unique objet de permettre la ratification d'un traité ; les lois de programmation qui déterminent les objectifs de l'action de l'État ; les lois d'habilitation ; les ordonnances non ratifiées qui ont de ce fait le caractère d'un acte réglementaire *(Cons. const., 10 février 2012, n° 2012-219 QPC)* ou encore, de façon plus générale, les dispositions d'une loi qui sont dépourvues de toute portée normative
- Dans le même ordre d'idée, le Conseil constitutionnel se refusant à contrôler, dans le cadre du contrôle qu'il exerce *a priori*, la constitutionnalité d'une loi se bornant à transposer fidèlement une directive, sous la seule réserve que cette dernière n'aille pas « *à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France* » *(Cons. const., 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information)*, il a logiquement estimé qu'il ne lui appartenait pas davantage de statuer sur de telles dispositions dans le cadre d'une QPC lorsque les trois conditions étaient remplies : la disposition législative se borne à transposer fidèlement les dispositions d'une directive, les dispositions de la directive sont précises et inconditionnelles et, enfin, les dispositions ne mettent pas en cause une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France *(Cons. const., 17 déc. 2010, n° 2010-79 QPC)*.
- Enfin, une QPC ne pourrait avoir pour objet d'interroger le Conseil constitutionnel, à titre préjudiciel, sur l'interprétation d'une norme constitutionnelle en vue de son application dans un litige *(CE, 16 avril 2010, Virassamy)*.

[27] « La modification ou l'abrogation ultérieure de la disposition contestée ne prive pas un justiciable du droit de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit au sens de l'article 61-1 de ce texte. En effet, la modification ou l'abrogation ultérieure de la disposition contestée ne fait pas disparaître l'atteinte éventuelle à ces droits et libertés. Elle n'ôte donc pas son effet utile à la procédure voulue par le constituant, et par suite, ne peut faire obstacle, par elle-même, à la transmission de la question au Conseil constitutionnel au motif de l'absence de caractère sérieux de cette dernière » *(Cons. const., 23 juillet 2010, n° 2010-16 QPC*).

En second lieu, **le grief formulé** à l'encontre d'une disposition légale doit soutenir que celle-ci porte **atteinte aux *« droits et libertés que la Constitution garantit »*.**

- Ces derniers sont répartis dans l'ensemble du *« bloc de constitutionnalité »* qui comprend, outre les articles du corps de la Constitution : la Déclaration de 1789, les principes particulièrement nécessaires à notre temps énoncés par le préambule de la Constitution de 1946, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, la Charte de l'environnement et, enfin, les droits et libertés figurant implicitement dans la Constitution consacrés par le Conseil constitutionnel. Pour autant, la notion demeure floue.
- Comme il n'existe aucune liste exhaustive des droits et des libertés entrant dans le champ d'application d'une QPC, c'est au Conseil constitutionnel qu'il est donc revenu de déterminer, au fil de ses décisions, ce qu'il convient d'entendre par les « droits et libertés » au sens de l'article 61-1 de la Constitution.

En troisième lieu, les tribunaux et cours d'appels saisis d'une QPC répondant aux exigences précédentes sont tenus d'examiner si le moyen soulevé répond à **trois conditions** qui doivent être **remplies de façon cumulative** pour que la QPC soit transmise, non pas directement au Conseil constitutionnel, mais à la juridiction suprême de l'ordre juridictionnel concerné (Cour de cassation ou Conseil d'État) :

1. **La question doit être relative à une disposition légale susceptible d'être appliquée au cours de l'instance** introduite devant la juridiction saisie du litige. Cela suppose, *a minima*, que la disposition concernée soit entrée en vigueur.
2. **La question doit être inédite**, ce qui implique que la disposition contestée ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances survenu depuis lors.
    - Un tel « changement des circonstances » peut être caractérisé par **l'inscription de nouveaux droits ou de nouvelles libertés dans le bloc de constitutionnalité**[28]. Il a même été jugé par le Conseil qu'une **évolution de sa propre jurisprudence** pouvait constituer un changement des circonstances de droit *(Cons. const., 5 juillet 2013, n° 2013-331 QPC)*.
    - En sens inverse, un « changement des circonstances » peut être caractérisé en cas de **modification des dispositions législatives contestées** depuis leur déclaration de conformité par le Conseil constitutionnel, ou encore lorsqu'une disposition à laquelle renvoie la disposition attaquée a été modifiée ou censurée *(Cons. const., 13 juillet 2012, n° 2012-264 QPC ; Cons. const., 6 mai 2011, n° 2011-125 QPC).*
    - Enfin, une **évolution de l'interprétation jurisprudentielle de la disposition contestée** peut constituer un changement des circonstances de droit, à la condition que cette jurisprudence émane du Conseil d'État ou la Cour de cassation, et non d'une juridiction inférieure (*Cons. const., 8 avril 2011, n° 2010-120 QPC*).
    - En revanche, la circonstance que le Conseil constitutionnel ait déclaré conforme une disposition législative en l'examinant au regard d'un autre moyen d'inconstitutionnalité que celui soulevé dans le cadre de la QPC est sans incidence. En effet, le Conseil constitutionnel a de très larges pouvoirs pour soulever d'office tout moyen d'inconstitutionnalité, c'est pourquoi il y a une **présomption d'analyse d'office de tous les moyens d'inconstitutionnalité lorsque le Conseil constitutionnel rend une décision de conformité à la Constitution**, même lorsque des moyens bien spécifiques avaient été invoqués par les auteurs de la première saisine.
3. **La question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux**. Il s'agit surtout ici de filtrer les « questions fantaisistes, dilatoires ou dépourvues de consistance », qui auraient pour but ou pour effet de retarder inutilement le jugement de l'affaire. Il existe toutefois, à cette occasion, un risque de préjugement de la constitutionnalité de la loi, spécialement lorsque le refus de transmettre la QPC est fondé sur ce seul critère.

[28] A titre d'exemple, l'inscription d'un nouvel alinéa à l'article 4 la Constitution, à l'occasion de la révision constitutionnelle du 28 juillet 2008, a pu être regardée comme un « changement des circonstances » par le Conseil constitutionnel justifiant le réexamen de dispositions relatives à la publicité des parrainages des candidats à l'élection présidentielle, *Cons. const., 21 févr. 2012, n° 2012-233 QPC*).

C. La décision rendue en réponse à la QPC

**La décision rendue par une juridiction de premier ou de second degré :**

- Si elle estime que les conditions de recevabilité de la QPC sont réunies, la juridiction saisie la transmet à la juridiction suprême de son ordre juridictionnel et doit, en principe, surseoir à statuer sur le litige principal (il est toutefois fait exception à cette règle lorsque certaines questions litigieuses doivent être jugées en urgence, et spécialement en matière pénale lorsqu'une partie fait l'objet d'une mesure privative de liberté). La transmission de la question au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation constitue donc un incident de procédure. Pour autant, le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
- Si, au contraire, ces conditions ne sont pas réunies, la juridiction tranche le litige sans transmettre la QPC. La décision de ne pas transmettre la QPC peut être contestée, mais seulement en même temps et par la même voie de recours que la décision rendue par le juge le litige principal, ce qui suppose d'attendre le prononcé d'une telle décision.

**La décision rendue par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation :**

- Ces juridictions sont chargées de déterminer s'il y a lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la QPC. A cette fin, elles doivent vérifier que la question est bien relative à une disposition légale susceptible d'être appliquée au cours de l'instance, qu'elle est bien inédite et qu'elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux, et ce quand bien même elles seraient saisies sur renvoi d'une juridiction inférieure, laquelle aura déjà procédé à un tel examen (les autres conditions de recevabilité ne sont en revanche examinées que si la QPC est formée pour la première fois à hauteur de cassation).
- Elles statuent dans un délai de 3 mois à compter de leur saisine, par une décision insusceptible de recours.

**La décision rendue par le Conseil constitutionnel** :

- Lorsque la question lui est renvoyée, il dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer, au terme d'une procédure contradictoire et par une décision motivée.
- S'il déclare que la disposition législative contestée est conforme à la Constitution, la disposition conserve sa place dans l'ordre juridique interne et la juridiction saisie du litige au fond devra en faire application en tenant compte des éventuelles réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel, sauf à ce qu'elle la juge par ailleurs incompatible avec d'autres normes supérieures à la loi (droit international ou européen).
- S'il déclare que la disposition législative contestée est contraire à la Constitution, il résulte de l'article 62 de la Constitution que cette disposition est en principe abrogée à compter de la publication de la décision. Cela signifie qu'elle disparaît de l'ordre juridique et qu'elle ne sera pas appliquée ni à l'auteur de la QPC, dans le litige à l'occasion duquel il l'a soulevée, ni aux instances en cours ou à venir à la date de la publication de la décision du Conseil.
    - Les dispositions de la Constitution permettent toutefois au Conseil constitutionnel de fixer la prise d'effet de l'abrogation à une date ultérieure qu'il détermine dans sa décision, afin de permettre au législateur de disposer d'un délai suffisant pour corriger l'inconstitutionnalité de la loi
    - Le Conseil constitutionnel peut également déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Il peut, à ce titre, prévoir par exemple que le législateur devra adopter des dispositions législatives relatives aux instances en cours.
    - En outre, en raison de l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, aux décisions du Conseil constitutionnel, une déclaration d'inconstitutionnalité relative à des dispositions législatives doit être regardée comme s'appliquant également aux dispositions « identiques, dans leur substance et dans leur rédaction » qui pourraient figurer dans un autre texte. Dans ce cas, le requérant peut bénéficier des effets de la déclaration

d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau ce dernier.

### II. La QPC, source de nouveaux rapports entre le juge de cassation et la constitution

En confiant au Conseil d'État et à la Cour de cassation le soin d'apprécier si la QPC doit être ou non posée au Conseil constitutionnel, la révision du 23 juillet 2008 marque une nouvelle étape dans les relations entre les hautes juridictions et la norme suprême constitutionnelle.

Le Conseil d'État et la Cour de cassation deviennent en quelque sorte des « juridictions constitutionnelles » :

- Le juge de cassation joue le rôle de « juge constitutionnel négatif », en ce sens qu'il peut rejeter les griefs d'inconstitutionnalité soulevés devant lui et refuser de renvoyer la QPC.
- En revanche, il ne joue pas un rôle de « juge constitutionnel positif », car seul le Conseil constitutionnel a le pouvoir de déclarer une disposition législative contraire à la Constitution.

A l'égard du Conseil d'Etat, la QPC constitue en outre une dérogation à la théorie de la loi-écran qui étend son pouvoir habituel de contrôle du respect de la hiérarchie des normes.

- Selon cette théorie, le juge administratif ne peut contrôler au regard de la Constitution un acte administratif pris sur le fondement d'une loi : parce que cette dernière est l'expression de la volonté générale, elle forme comme un « écran » entre l'acte administratif et la Constitution (CE, Sect., 6 novembre 1936, Arrighi). Si cette théorie n'est pas remise en cause en elle-même, elle cesse de s'appliquer, en vertu de l'article 61-1 C., lorsque le grief formulé contre la loi-écran est tiré de son inconstitutionnalité.
- Le mécanisme de la QPC simplifie donc considérablement la mission du Conseil d'Etat en présence d'une loi inconstitutionnelle, car auparavant, la haute juridiction avait dû recourir à une technique complexe pour tempérer les conséquences de l'écran législatif lorsque les dispositions légales étaient incompatibles avec des dispositions constitutionnelles. Plus précisément, le Conseil d'Etat avait recours à la technique dite de « l'abrogation implicite » de la loi par la Constitution, lorsque la Constitution était postérieure à la loi[29].

## CHAPITRE 2 : LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Il faut bien comprendre qu'il y a deux Europes, et donc deux juridictions européennes nettement distinctes, de sorte qu'il faut se garder de confondre la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) est une juridiction créée en 1959 **dans le cadre du Conseil de l'Europe**.

- Ce dernier est une institution intergouvernementale créée en 1949 dans le cadre du traité de Londres, dont la mission est, à la suite de la seconde guerre mondiale, d'assurer la protection de la démocratie et de la prééminence du droit en Europe. Pour cela, le Conseil élaborera notamment un traité dont l'unique objet est la protection des droits de l'homme : la **Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales** (1953).
- La CEDH est l'organe chargé d'assurer que chaque État-partie à la Convention en respecte les termes sur son territoire. **Elle siège à Strasbourg**.

[29] « Considérant que s'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité d'une loi aux dispositions constitutionnelles en vigueur à la date de sa promulgation, il lui revient de constater l'abrogation, fût-elle implicite, d'un texte de loi qui découle de ce que son contenu est inconciliable avec un texte qui lui est postérieur, que celui-ci ait valeur législative ou constitutionnelle » *(CE, Sect. 12 février 1960, Société Eky, req. n°46922 et n°46923 ; CE, 21 novembre 2005 Boisvert, req. n°287217).*

- Aujourd'hui, le champ de compétence de la CEDH dépasse largement les frontières géographiques de l'Europe. Ainsi, 46 Etats sont signataires de la CSHDLF, dont la Turquie et l'Azerbaidjan. La Russie était initialement un Etat signataire de la Convention, mais en raison de son exclusion du Conseil de l'Europe le 22 mars 2022, elle a cessé d'être partie au traité à compter du 16 septembre 2022.

La CEDH **se compose d'autant de juges que d'Etats-membres**.

- Ces juges sont élus par l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe à partir d'une liste de 3 personnes présentée par chaque Etat. Leur mandat est de 9 ans est n'est pas renouvelable. La limite d'âge est de 65 ans au moment de la nomination.
- La Cour statue en principe en chambre (7 juges), qui comprennent obligatoirement le juge élu par l'Etat défendeur ; mais lorsqu'une affaire pose une difficulté particulière, ou lorsque l'une des parties conteste une décision de chambre dans les 3 mois de son prononcé, la Cour statue en formation dite « Grande chambre », composée de 17 juges (dont le juge élu par l'Etat défendeur).

**La CEDH peut être saisie par** :

- Un Etat signataire de la Convention.
- Depuis 1981 en France, par une personne privée. Pour qu'une personne physique ou morale puisse saisir la CEDH, il faut qu'elle ait épuisé en vain toutes les voies de recours internes (ce qui implique d'avoir formé un recours devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation). Elle dispose alors d'un délai de quatre mois pour saisir la CEDH.
- A noter que **le défendeur sera toujours un Etat-membre** : quelle que soit l'identité du demandeur, il s'agira de déterminer si l'Etat attaqué devant la CEDH a ou non violé un droit de l'homme protégé par la CSHDLF.

**La décision de la CEDH n'a qu'une seule conséquence juridique** : **l'Etat condamné doit indemniser le requérant**.

- Cela signifie que la violation des droits de l'homme se répare avant tout financièrement
- En théorie, les États-parties sont également obligés de se conformer aux décisions de la CEDH, ce qui implique de rectifier la situation à l'occasion de laquelle une violation de la CSHDLF a été commise. Mais **la seule décision de la CEDH n'entraîne pas l'annulation de la décision de justice rendue en violation de la Convention** : il faut pour cela que l'Etat concerné ait prévu une procédure de réexamen à la suite d'une décision de condamnation prononcée par la CEDH. C'est le cas en France mais à des conditions très étroites.

On notera que **la CEDH peut aussi être saisie pour avis**, par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, afin de se prononcer sur une question de principe relative à l'interprétation ou l'application des droits et libertés définis par la Convention (et ses protocoles additionnels). L'intérêt de cette procédure est qu'elle permet de connaître à l'avance la position de la CEDH sur une question litigieuse, et d'éviter ainsi de rendre une décision qu'elle condamnerait par la suite.

# CHAPITRE 3 : LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE

Historiquement, l'Union européenne n'était qu'une communauté économique entre six Etats. Depuis le traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 2009), il s'agit d'une institution politique qui rassemble 27 Etats et qui est organisée comme un super-Etat, en ce sens que l'Union fonctionne comme un Etat à part entière, mais dans des domaines de compétence restreints, en dehors desquels chaque Etat-membre conserve sa souveraineté.

Ainsi, l'Union européenne est dotée d'un Conseil des ministres, d'une Commission européenne, d'un Parlement européen et d'une juridiction…qui **siège au Luxembourg** et se divise en deux.

- En effet, la **Cour de Justice de l'Union Européenne** (ancienne CJCE) étant débordée, elle s'est vu adjoindre un **Tribunal de l'union européenne**, sorte de chambre autonome qui a un champ de compétence plus réduit et sert à décharger la Cour d'une partie de ses dossiers. Vu son domaine de compétence, ce tribunal ressemble à une sorte de juge administratif de l'UE, et à terme on pourrait envisager une répartition des compétences similaires à celle qui a lieu en France, la CJUE se réservant le contentieux judiciaire au sein de l'Union.
- **La Cour** est composée d'autant de juges que d'Etats-membres, leur mandat est de 6 ans, ils sont désignés d'un commun accord par les Etats-membres. Ils sont renouvelés tous les 3 ans par moitié. Elle siège en chambre (10 juges), en grande chambre (15 juges) ou en assemblée plénière (tous les juges).
- **Le Tribunal** est composé de 2 juges par Etats, nommés et renouvelés dans les mêmes conditions que les juges de la CJUE. Les formations sont également les mêmes, à ceci près que pour certaines matières le tribunal statue à juge unique. Les décisions du tribunal peuvent être contestées devant la CJUE, qui fait alors office de juridiction de cassation.

La CJUE (de façon générale) **a pour fonction première d'assurer le respect du droit de l'UE par l'ensemble des Etats-membres**.

- A cette fin, elle **peut être saisie directement n'importe quelle juridiction interne pour avis** (on parle de question préjudicielle) afin qu'elle livre par avance son interprétation d'une règle de droit européen.
- Contrairement à la CEDH, **il n'est pas possible pour un justiciable d'un Etat-membre se de plaindre devant la CJUE d'une violation de ses droits fondamentaux par ledit Etat**. Seuls les Etats (ou une institution européenne) peuvent s'assigner mutuellement devant la CJUE pour non-respect, dans leur ordre interne, du droit de l'UE (recours en manquement)
- **En revanche, il est possible à un justiciable d'agir devant la CJUE pour se plaindre d'une règle de droit de l'Union qui lui est applicable** : il peut demander l'annulation d'un texte issu d'une des institutions européennes, ou des dommages-intérêts si cet acte affecte injustement sa situation, voir se plaindre de ce qu'un acte qui aurait dû être pris par une institution européenne ne l'a pas été (« recours en carence »)
- On a donc **deux configurations, en fonction de l'objet du recours** :
    - soit il s'agit de se plaindre d'un manquement, par un Etat-membre, du respect des règles de l'UE. Dans ce cas, le demandeur est forcément un autre Etat-membre ou la Commission européenne.
    - soit il s'agit d'agir contre une institution européenne (par exemple la Commission), pour l'obliger à adopter un texte en application du traité fondateur, ou au contraire pour faire annuler un texte contraire au traité fondateur. Le demandeur peut alors être un Etat ou un particulier de cet Etat.

# THEME II – LES GRANDS PRINCIPES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE FRANÇAISE

La faculté, en cas de litige, de le soumettre à un juge afin qu'il y mette fin, et dise qui a tort ou raison, est fondamentale dans un Etat de droit, de sorte que plusieurs règles tendent à garantir l'effectivité du droit d'agir en justice (PARTIE I). Par ailleurs, tout procès se doit se dérouler dans le respect de principes fondamentaux qui assurent, là encore, l'effectivité du droit d'obtenir justice (PARTIE II). L'Etat qui n'assure pas de façon efficace la protection des droits fondamentaux des justiciables est susceptible d'engager sa responsabilité envers ceux-ci (Partie III).

## PARTIE I – LES PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE

Rendre la justice est une mission de service public pour l'Etat : c'est un devoir qui lui incombe dans le cadre du contrat social, dès lors qu'il accapare la faculté d'user de violence pour pacifier la société. Il doit donc s'assurer que la justice sera rendue de façon satisfaisante, et pour cela, que tous les justiciables seront égaux devant la justice (TITRE I), que le coût du procès ne les découragera pas de faire valoir leurs droits en justice (TITRE II), et que les juridictions rendront la justice en continu (TITRE III).

### TITRE I – LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE

C'est avant tout une manifestation du principe d'égalité devant la loi proclamé par l'article 1er de la DDHC.

Il est à noter que le principe d'égalité devant la justice bénéficie à tout justiciable se trouvant en litige devant une juridiction de la République, et pas seulement aux ressortissants français.

Ce principe implique :

- Que les règles procédurales applicables aux litiges (charges au cours de la procédure, délais de recours, formalisme et modes de jugement) soient, sauf motif légitime, les mêmes pour tous les justiciables. On parle à ce titre d'égalité des « armes ».
- Les juridictions doivent être les mêmes pour tous. Pas de privilège de juridiction au profit de certaines catégories de justiciables, comme cela avait cours sous l'Ancien Régime. Il n'est donc pas possible d'être jugé par une juridiction créée spécialement pour les besoins d'un litige. Mais cela n'empêche pas certaines spécialisations lorsqu'elles sont légitimes (cf. les juridictions d'exception, ou les juridictions pour mineurs). On parle ici d'égal accès aux tribunaux (ou parfois de « droit au juge naturel »).
- Le droit appliqué par les juridictions doit être le même pour tous. C'est d'ailleurs pour cela que la Cour de cassation se voit investie de la mission d'harmoniser les décisions de justice rendues par les juridictions de premier et de second degré.

Le principe d'égalité comporte néanmoins des **limites**, d'ordre juridique et surtout factuelles :

- **Limites juridiques** : il peut arriver que certaines règles avantagent l'Etat lors d'un procès. Elles seront étudiées dans le fascicule consacré à la justice administrative. En matière pénale, outre les règles exposées dans le fascicule dédié à la justice pénale, on peut citer le délai d'appel du procureur, qui est de 20 jours là où les particuliers n'ont que 10 jours. Autre exemple significatif : les Etats étrangers bénéficient d'immunité de juridiction, de sorte qu'ils ne peuvent être condamnés par des juridictions françaises ; l'Etat français bénéficie pour sa part d'une immunité d'exécution : lorsqu'il ne se conforme

pas spontanément à la décision le condamnant, il est impossible d'envoyer un commissaire de justice saisir des biens publics, comme on enverrait un commissaire de justice saisir les biens d'un débiteur personne privée.

- **Limites factuelles :** il s'agit des inégalités économiques et sociales. En effet, le procès a un coût non négligeable, et sa lenteur peut être dissuasive, surtout si la partie la plus aisée fait tout son possible pour retarder l'issue du litige et accroître la pression financière sur son adversaire. Pour y remédier, on peut envisager de confier l'action en justice à des groupements qui représenteront collectivement l'intérêt d'individus isolés, qui ne défendraient sans doute pas leurs droits s'ils devaient agir eux-mêmes : cela a été le cas en droit du travail, où les syndicats peuvent ainsi défendre les intérêts de salariés ; il est également possible que des associations soutiennent l'action en justice d'un justiciable et assument le coût de son procès ; la création, à partir de 2014, d'actions de groupe dans des domaines diversifiés, permet également la défense groupée d'intérêts individuels par une association investie de cette mission par l'Etat. Enfin, et surtout, l'Etat s'efforce de réduire le coût des procès pour les justiciables, ce que l'on va étudier à l'occasion du principe suivant.

## TITRE II – LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE

L'article L. 111-2 COJ proclame que le service public de la justice est gratuit, mais « dans les modalités fixées par la loi et les règlements ».

- Concrètement, cela signifie que, si les plaideurs n'ont plus à payer les juges (abandon du système des épices, contrepartie des charges, avec la fonctionnarisation des juges à la Révolution), il n'en reste pas moins que le fonctionnement des juridictions représente un coût pour l'Etat en termes de matériel et de personnel, que la fiscalité seule ne permet pas d'assurer.
- La gratuité totale pour tous n'est donc pas possible, et il faut répartir la charge des procès tant sur la collectivité que sur les usagers du service public de la justice. Toute la question devient alors celle de l'équilibre politique de cette répartition, qui impacte l'égal accès de tous à la justice.

Tout procès à un coût :

- Jusqu'en 1978, l'Etat auto-finançait les procès par le biais de la perception de frais divers sur les actes de procédure : droits de timbres, d'enregistrement, de greffe, frais de procédure divers…tout ce que l'on nomme les « débours ».
- En 1978, l'Etat a décidé de supprimer ces frais en instaurant la gratuité des actes de procédure en matière judiciaire (sauf en matière commerciale, au regard de la particularité de la juridiction consulaire) et administrative. La France était alors l'un des très rares pays d'Europe ou l'accès à la justice de premier degré était totalement gratuit (l'Allemagne et l'Autriche pratiquent au contraire des taxes très élevées de procédure).
- Des considérations budgétaires ont récemment incité l'Etat à restaurer des droits de timbre. Ainsi, un décret de 2011 a créé une taxe de 35 euros (appelée « contribution pour l'aide juridique »), ainsi qu'une taxe (en appel) de 150 euros affectés au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, les deux taxes étant prévues à peine d'irrecevabilité de la demande. Compte tenu des vives critiques formulées contre ces taxes, celle de 35 euros a été supprimée par un décret de 2013, avant d'être recréée, à compter du 1er mars 2026, par la loi de finance pour 2026, complétée par le décret n°2026-250 du 7 avril 2026, et portée à un montant de 50 euros, sous la forme d'une « contribution pour l'aide juridique » prévue à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts. Quant à celle de 150 euros, censée être temporaire, elle a vu sa durée prolongée jusqu'au 31 décembre 2026, et son montant augmenté à 225 euros. Ces différents frais d'accès au juge, y inclus la « contribution pour la justice économique » instaurée à l'occasion de la création des tribunaux aux activités économiques *(cf. volume 2)*, mettent à mal le principe de gratuité de la justice proclamé par l'article L. 111-2 COJ, nonobstant les cas de dispense qu'elles prévoient. Ils n'en ont pas moins été jugés conforme à la Constitution par le conseil constitutionnel, nonobstant la sanction radicale du défaut d'acquittement de la somme due à leur titre – l'irrecevabilité des prétentions assujetties.

- Cela étant, il faut relativiser, car la gratuité de la justice n'a jamais signifié qu'elle n'a aucun coût : les parties doivent payer les honoraires (émoluments) des auxiliaires de justice (avocats, commissaires de justice, greffe des tribunaux de commerce, etc.).

Les spécificités du coût du procès civil :

Le principe d'une gratuité totale n'ayant pas pu être maintenu, il existe aujourd'hui deux types de frais procéduraux : **les dépens** d'une part, les **frais irrépétibles** de l'autre.

- **Les dépens** : ce sont des frais dont l'engagement est **nécessaire au déroulement du procès** (on ne peut pas en faire l'économie) et qui font l'objet d'une **tarification judiciaire.** Ils sont limitativement énumérés par l'article 695 CPC (par exemple, les indemnités des témoins ; la rémunération des commissaires de justice, appelée « émoluments » ; la rémunération des techniciens…). Chaque partie avance ses propres dépens, mais a la possibilité, en cas de victoire, de se les faire rembourser par la partie adverse (le perdant[30] supporte donc la totalité du coût du procès : ses dépens, et ceux de l'adversaire). Il peut toutefois être dérogé à cette règle sur décision du juge (en particulier lorsque l'existence de certains dépens et imputable à l'une des parties spécifiquement). A noter qu'en vertu de l'article 698 CPC, les actes accomplis de façon injustifiée ou irrégulière par les auxiliaires de justice restent à la charge de ceux-ci, puisqu'ils procèdent d'une faute de leur part (on parle de « frais frustratoires »).
- Les **frais irrépétibles** : le mot vient du latin « petere », réclamer ; il s'agit des frais dont on ne peut normalement pas réclamer le remboursement à la partie adverse parce qu'ils ne sont pas inclus dans la liste limitative des dépens. Donc, littéralement, tout frais procédural qui n'est pas un dépens fait partie des frais irrépétibles, et en particulier les honoraires des avocats. Mais l'article 700 CPC permet de solliciter du juge, sur un critère d'équité, qu'il condamne la partie tenue de rembourser les dépens à l'adversaire (en principe la partie perdante) à lui rembourser également ses frais « exposés et non compris dans les dépens » (les frais irrépétibles deviennent alors répétibles).

**FOCUS SUR LA « CONTRIBUTION POUR L'AIDE JURIDIQUE »**

L'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, complétée par le décret n°2026-250 du 7 avril 2026 tel qu'interprété par sa circulaire de présentation JUSC2609612C (n°CIV/03/26), crée un **article 1635 *bis* Q du code général des impôts** en vertu duquel le **demandeur doit verser une « contribution pour l'aide juridique »** sous la forme d'un « timbre justice » d'un montant fixé (pour l'instant) à **50 euros**. Cette contribution doit être acquittée par voie électronique par le biais de l'achat du timbre fiscal, et elle est reversée mensuellement par l'Etat à l'Union nationale des caisses autonome de règlement pécuniaire des avocats (UNCA).

***Ratione temporis***, cette contribution est **due** dans toutes les **instances introduites à compter du 1er mars 2026**.

***Ratione juridictionis,*** cette contribution n'est due qu'en cas d'action formée devant le tribunal judiciaire ou le conseil de prud'hommes. Le tribunal de commerce et le tribunal paritaire des baux ruraux en sont donc affranchis (mais une « contribution pour la justice économique » existe devant les douze tribunaux de commerce convertis à titre expérimental en « tribunaux des activités économiques »). Saisir la cour d'appel implique déjà, jusqu'à la fin de l'année 2026 *(mais une prorogation est probable)*, de l'obligation pour l'appelant principal de s'acquitter d'un « timbre fiscal » de 225 euros, destiné au financement du fonds créé à la suite de la suppression du ministère d'avoué.

***Ratione materiae,*** la contribution pour l'aide juridique est due **par le seul demandeur initial** (donc pas le demandeur incident) ; le montant est due au titre de l'instance introduite devant le tribunal, donc il ne varie

[30] On notera que, pour la Cour de cassation, une action en référé 145 CPC ne comporte ni gagnant ni perdant, de sorte que chaque partie doit supporter ses propres dépens *(Cass. 2ème civ., 21 novembre 2024, n°22-16763)*, au contraire, par exemple, d'un référé remise en état, y compris lorsqu'avant d'ordonner la remise en état le juge des référés fait évaluer les modalités et le coût de celle-ci par un expert *(Cass. 2ème civ., 22 octobre 2015, n°14-24848)*.

ni en cas de pluralité de demandes initiales, ni en cas de pluralité de demandeurs initiaux (lesquels se partagent alors le montant de 50 euros). Et **lorsque plusieurs actions connexes sont successivement exercées, alors la contribution n'est due qu'au titre de l'instance introduite par la première d'entre elles** *(par ex., référé in futurum puis action au fond ; ou encore, action devant un juge incompétent renvoyée devant la bonne juridiction, sauf si le juge incompétent n'était pas TJ ou un CPH et que le dossier est renvoyé devant l'une de ces deux juridictions, car alors la contribution n'aura pas déjà été acquittée)*. **En revanche, si l'instance prend fin par la péremption, le désistement, ou la caducité** – soit un comportement imputable du demandeur initial – alors il devra **à nouveau régler la somme de 50 euros** s'il souhaite **réitérer sa demande** *(on observera que sur ce point, la contribution pour l'aide juridique diffère étonnamment de la contribution pour la justice économique dont doit s'acquitter la partie qui saisit un TAE).*

Les articles 62 à 62-3 CPC énumèrent les **cas de dispense**. On retiendra surtout :

- Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle
- Les procédures de surendettement des particuliers
- Les affaires de violences au sein du couple
- La procédure d'injonction de payer dans sa totalité *(en revanche la contribution est due au titre de la procédure d'injonction de faire)*
- Les procédures aux seules fins d'homologation d'un accord *(finalité qui ne correspond pas à une « demande »)*.

La **sanction** prévue en cas de défaut de règlement de cette contribution est **l'irrecevabilité de la demande**, que le juge ne peut toutefois prononcer qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du moment où le greffe aura sollicité du demandeur la régularisation de sa situation. **Cette sanction ne peut qu'être relevée d'office : les parties se voient retirer la qualité pour soulever la fin de non-recevoir correspondante (art. 62-5 CPC).**

- Au sein du tribunal judiciaire, la compétence pour prononcer cette irrecevabilité est attribuée, selon la phase et le cadre de la procédure, au président du tribunal, au président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, au JME ou à la formation de jugement. Outre un recours gracieux ouvert sous quinze jours devant le juge qui aurait prononcé la sanction par erreur, la décision d'irrecevabilité peut être attaquée par la voie, soit du recours qui aurait été ouvert contre la décision du fond, soit du recours ouvert contre les ordonnances d'irrecevabilité du JME mettant fin à l'instance.
- Au sein du conseil de prud'hommes, en l'absence de dispositions spécifiques, la circulaire considère seul le bureau de jugement est compétent.

Ces dispositions ont été jugées conformes à la Constitution *(Cons. const. 19 févr. 2026, n° 2026-901 DC).*

Les spécificités du coût du procès pénal :

- **Les dépens** correspondent au **coût des poursuites** (opération de police technique, indemnités des témoins, frais de citation, etc.). Avant 1993, les dépens étaient avancés par l'Etat, qui pouvait les récupérer sur la partie perdante. **Depuis une loi du 4 janvier 1993**, la solution retenue est inverse : parce que le procès pénal a pour objet la défense de l'intérêt général et que l'action publique est une action exercée au nom de l'Etat contre une personne suspectée d'être impliquée dans la commission d'une infraction, **il a été décidé que ce serait l'Etat qui supporterait le coût du procès** qu'il intente à une personne physique, et ce sans qu'il puisse obtenir leur remboursement par la personne poursuivie, même en cas de condamnation de celle-ci (art. 800-1 CPP). Naturellement, cette décision politique a fait exploser le coût de la justice pénale. A noter **toutefois** qu'un « **droit fixe de procédure** », fixé par l'article 1018 A du code général des impôts et dont le montant varie en fonction du type de décision rendue, continue à être prélevé sur la partie perdante (partie civile, ou personne poursuivie si elle est majeure).
- Les **frais de défense** sont **ceux engagés par les parties privées** (partie civile et personne poursuivie). Le principe est qu'ils demeurent à leur charge, le juge appréciant en équité, lorsque cela lui est demandé, si les frais de défense de la partie perdante peuvent être mis à la charge de la partie gagnante. Le tout sous réserve des règles applicables en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, ou de la commission d'un avocat d'office à la partie poursuivie.

Les spécificités du coût du procès administratif :

De façon générale, le coût du procès administratif est bien moindre que le coût des procès civil et pénal, dans la mesure où la dispense d'avocat est fréquente, et que la procédure est majoritairement écrite. On relèvera surtout l'existence :

- D'un **droit de plaidoirie**, établi par le décret n°2014-1704 du 30 décembre 2014.
- De **dépens** (le plus souvent occasionnés par des mesures d'instruction), mis à la charge de la partie perdante, sauf si celle-ci a été la cause de frais inutiles. Et encore y a-t-il des contentieux où les parties sont dispensées de toute obligation aux dépens (par ex., contentieux de l'expropriation ; contentieux des élections).
- Les **frais irrépétibles** sont mis à la charge de la partie perdante dans des conditions similaires au procès civil, en vertu de l'article L. 761-1 CJA.

L'aide à la prise en charge des coûts du procès :

Elle s'opère par le biais d'une aide financière accordée par l'Etat ou par des mécanismes d'assurance privés.

- **L'aide juridique** : c'est la prise en charge des coûts du procès par l'Etat. Depuis 1991, l'aide juridique a remplacé l'aide judiciaire. Elle a pour fonction d'assurer la dispense totale ou partielle des dépens ainsi que la prise en charge des frais d'avocat (aide « juridictionnelle »), mais aussi, et ce fut une nouveauté en 1991, d'assurer l'aide à la consultation et l'assistance juridique en dehors de toute procédure judiciaire (aide « à l'accès au droit »). Naturellement, l'aide juridique ne peut être sollicité que si l'on ne bénéficie pas d'une assurance privée remplissant les mêmes fonctions.
    - **L'aide juridictionnelle** : pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, il faut en principe être, soit une personne physique de nationalité française ou ressortissante d'un État de l'UE, soit une personne morale à but non lucratif (articles 2, 3 et 3-1 de la loi du 10 juillet 1991). La **qualité procédurale** (demandeur/ défendeur) de celui qui prétend au bénéfice de l'aide juridictionnelle est **indifférente** (sauf le cas de la demande « manifestement irrecevable ou dénuée de fondement » et, depuis la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 entrée en vigueur sur ce point le 1er décembre 2020, la demande « manifestement abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique » (quérulence), qui écarte d'emblée le demandeur de l'aide juridictionnelle). Aux termes des **articles 4 à 7 de la loi du 10 juillet 1991, sont prises en compte les ressources des plaideurs** (établi, depuis la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 entrée en vigueur sur ce point le 1er janvier 2021, par leur revenu fiscal de référence), **leurs charges de famille et,** depuis la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 entrée en vigueur sur ce point le 1er janvier 2021, **leur capital mobilier** (ce qui inclut donc l'épargne) **et immobilier** (mais sont exclus la résidence principale et le local commercial)**.**
        - ❖ Concrètement, le justiciable doit adresser une demande au « bureau d'aide juridictionnelle », lequel dispose d'un droit de communication d'informations auprès des administrations pour vérifier la condition liée aux ressources (ce qui est facilité depuis 2021 par la mise en place d'un système informatique simplifiant la procédure demande et de vérification, notamment en passant par FranceConnect). L'aide accordée peut être retirée en cas de déclaration inexacte ou mensongère, de survenance de ressources ou si le caractère abusif ou dilatoire de la procédure est avéré (art. 50 de la loi du 10 juillet 1991). Le refus ou le retrait de l'aide doit être motivé et peut être contesté.
        - ❖ L'aide **peut être** soit **totale**, soit **partielle**, suivant les ressources du requérant (en 2023, totale pour les revenus d'une personne seule inférieurs ou égaux à 1022,5 euros, partielle entre cette somme et 1533,5 euros). Elle **recouvre tous les frais et émoluments dus par le demandeur** de l'aide aux différents auxiliaires de justice dont la procédure requiert le concours, c'est-à-dire, **les dépens du bénéficiaire**, **et aussi l'assistance d'un avocat** (libre choix, mais pour l'avocat aussi ; si l'avocat n'accepte pas, le bâtonnier désigne un autre avocat)**. Toutefois**, **en cas de défaite, les dépens de l'adversaire restent dus** par le bénéficiaire de l'aide et ne sont pas pris en charge par celle-ci (sauf décision contraire du juge). De même, si le bénéficiaire de l'aide

juridictionnelle est condamné aux **frais irrépétibles**, ceux-ci **ne sont pas non plus pris en charge**.

- **L'aide à l'accès au droit** : elle a pour **objet** de **prendre en charge**, là encore sous condition de ressources, les **frais** rendus nécessaires par la **défense des droits en dehors du cadre juridictionnel**. **Exemples** de ce type de frais : information générale des individus sur leurs droits et obligations ; accomplissement de démarches et procédures autres que la saisine d'une juridiction (conciliation, médiation…) ; consultation d'un professionnel du droit ; assistance à la rédaction d'actes juridiques (contrats, mises en demeure, etc.).

- **L'assurance de protection juridique** : c'est une opération qui consiste, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge les frais de procédure ou à fournir des services de conseil à un assuré, qu'il soit demandeur ou défendeur à une procédure, ou dans le cadre de la négociation amiable de la réparation d'un dommage qu'il a subi.

# TITRE III – LE PRINCIPE DE CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

Au regard du caractère essentiel de la mission de juger les litiges, on peut se demander si le service public de la justice ne devrait pas fonctionner sans interruption.

Ce n'est pas le cas dans tous les pays (par ex., en Grande-Bretagne), mais c'est le cas en France (**art. L. 111-4 COJ**), même si cela implique parfois des conditions de procès dégradées : par exemple, pendant la crise sanitaire, beaucoup d'affaires ont dû être jugées sans aucune audience, ou alors par téléconférence (sachant que les tribunaux n'étaient pas du tout équipés pour ça, et les justiciables parfois non plus…).

- Cela implique qu'il n'existe **pas de « vacances judiciaires »** : les tribunaux sont ouverts toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre (art. R. 111-1 COJ). Les chefs de juridiction ont donc la charge d'organiser des périodes de repos par roulement entre les magistrats de leur juridiction, de façon qu'une permanence soit toujours assurée.
- C'est aussi ce qui explique que les magistrats de l'ordre judiciaire n'aient pas le droit de grève (à l'image de la police, des gardiens de prison et des contrôleurs aérien…). En revanche, l'ordonnance de 1958 ne s'appliquant pas aux magistrats de l'ordre administratif, ceux-ci ne pourraient se voir interdire le droit de grève que par une disposition *ad hoc*, laquelle n'a jamais été adoptée à ce jour.
- Et si les juridictions ne siègent pas les jours fériés et le dimanche, certains juges doivent continuer à assurer leur fonction pendant ces périodes (juge des référés notamment, dont on parlera en détail par la suite).
- Il faut toutefois tenir compte du fait que certaines juridictions ne siégent pas de façon permanente mais par session (Cour d'assises, TPBR…).

Pour autant, et afin de respecter des conditions de travail décentes réclamées par les syndicats de magistrats, une circulaire de 2001 a décidé qu'en principe une demi-journée d'audience ne pouvait durer plus de 6 heures, et une audience ininterrompue sur la journée plus de 8h (ces durées incluant le temps de délibéré). Nonobstant, les conditions de travail des magistrats ne cessent de se dégrader, notamment en raison de contraintes budgétaires, au point qu'en 2021, 957 magistrats de l'ordre judiciaire ont bravé l'interdiction statutaire de faire grève dans le cadre d'une journée « Justice morte », afin de dénoncer leurs conditions de travail (ayant poussé au suicide certains de leurs collègues) ; ils ont été couverts implicitement par leur hiérarchie, dans les mesure où les chefs des cours d'appel dont ils dépendaient se sont contentés de leur infliger une retenue sur traitement au prorata du temps non travaillé, sans sanction disciplinaire.

# PARTIE II – LES PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS AU DEROULEMENT DE L'INSTANCE

On se concentrera sur la publicité de la justice (**TITRE I**) et la célérité de la justice (**TITRE II**), étant précisé que ces notions présentent, selon le type de juridiction concernée (civile, pénale ou administrative), des spécificités qui seront développées dans chacun des fascicules correspondants.

## TITRE I – LE DROIT A LA PUBLICITE DE LA JUSTICE

Ce principe signifie que le public doit pouvoir assister à un procès pour contrôler la façon dont la justice est rendue : c'est une garantie de bon fonctionnement du service public de la justice dans un Etat de droit en ce qu'elle favorise la soumission des individus aux jugements rendus par les juridictions de l'Etat *« justice must not only be done, it must be seen being done »*.

Le principe de publicité de la justice se décline en publicité de l'audience (c'est-à-dire des débats) et publicité du prononcé du jugement (proclamation solennelle).

Le principe de publicité de l'audience :

- Des dérogations au principe de publicité de l'audience sont admises pour des motifs légitimes. Cf. l'article 6 CSDHLF: *« le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès* ***dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties*** *au procès l'exigent,* ***ou*** *dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal,* ***lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice*** *»*. Le Conseil constitutionnel a érigé la publicité des audiences en principe à valeur constitutionnelle dans un décision 2019-222 du 23 mars 2019, tout en l'assortissant de limites similaires à celles prévues par la Convention européenne.
- **L'absence de publicité** en matière civile signifie que les débats se déroulent en « **chambre du conseil** » ; dans le cadre d'un procès pénal ou administratif, on dira qu'ils se déroulent à « **huis clos** ».
- En dehors des cas où l'intérêt d'une partie au procès justifie que celui-ci ne soit pas public (donc lorsque c'est justifié par des considérations de sécurité nationale ou de sérénité des débats ; par ex. risque terroriste ou sanitaire), il faut s'efforcer de trouver un compromis, par ex. une vidéotransmission de l'audience dans une salle accessible au public.
- **Si la publicité des débats implique la présence d'un public dans la salle d'audience, il est en revanche normalement interdit d'enregistrer les débats**.
    - L'enregistrement des audiences (ou de certaines mesures d'investigation) est parfois prévue, voire imposée par la loi, mais il est alors destiné à la justice elle-même (les enregistrements n'ayant pas vocation à être diffusés au public).
        - ❖ Par exemple, pour être utilisé comme preuve dans une procédure judiciaire *(cf. l'objectif explicite en ce sens de l'article 50 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice, qui prévoit à titre expérimental l'enregistrement de la notification des droits lors d'une garde à vue).*
        - ❖ Ou bien pour être utilisé dans le cadre de la révision d'un procès.
    - Par ailleurs, le code du patrimoine permet à titre dérogatoire des enregistrements à des fins de constitutions d'archives historiques de la justice (dits « enregistrements mémoriels »). Les procès présentant un intérêt historique peuvent ainsi être filmés (premier = procès de Klaus Barbie en 1987 ; plus récemment, procès Papon en 1998, ou procès AZF en 2009), mais la notion est interprétée très restrictivement (refus pour le procès du frère de Mohammed Merah en 2017). En matière pénale, la loi de réforme de la justice de 2019 permet au parquet d'imposer l'enregistrement des procès relatifs à des crimes contre l'humanité ou des actes de

terrorisme, et la diffusion de l'enregistrement peut avoir lieu dès que le procès a pris fin (première application = procès assassinat Charlie Hebdo).

- Dans le même ordre d'idée, la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a inséré un article 38 quater dans la loi de 1881 sur la presse qui permet l'enregistrement audio et vidéo d'une audience en vue de sa diffusion au public en cas de « motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique ». Les captations des audiences pourront être diffusées uniquement lorsque l'affaire aura été définitivement jugée, avec l'accord et dans le respect des droits des parties *(droit à l'image, respect de la vie privée, présomption d'innocence, droit à l'oubli, intérêt supérieur des mineurs ou des majeurs protégés)*. Toutes les personnes filmées, professionnels comme justiciables, devront remplir un formulaire de consentement.

Le principe de publicité du jugement :

En théorie, la publicité du prononcé du jugement ne souffre aucune exception (cf. la formule de l'art. 6 CSDHLF). Mais la CEDH elle-même a admis que cette « publicité » pouvait prendre la forme d'un simple dépôt du jugement au greffe de la juridiction (pas de lecture solennelle lors d'une audience de prononcé), dès lors que les tiers ont la possibilité de le consulter.

Depuis une loi de 2016 sur la République numérique, l'Etat travaille à rendre l'ensemble des décisions de justice, toutes juridictions confondues, à devenir librement consultables par voie numérique, après anonymisation : c'est l'« *open data* » des décisions de justice. Cela permettra notamment d'établir des données statistiques par le biais d'algorithmes mis au point par des « *legal techs* » ; néanmoins, il est interdit de dresser de telles statistiques à partir des données d'identité des magistrats et greffiers, en vue d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles. La loi de réforme de la justice de 2019 a poursuivi cette accessibilité des décisions de justice en restreignant toutefois la communication des décisions par les greffes lorsque les demandes présentées sont abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.

## TITRE II – LE DROIT A LA CELERITE DE LA JUSTICE

Le respect d'une durée raisonnable de jugement est la condition de l'efficacité et de la crédibilité de la justice.

- Les bornes prises en compte pour le calcul du délai sont la date de l'introduction de l'instance et la date d'exécution de la décision qui statue définitivement sur le bien-fondé de la demande (l'affaire est définitivement réglée, plus aucun recours n'est possible, et l'on inclut aussi les difficultés d'exécution lorsqu'il y en a).
- Le caractère raisonnable du délai s'apprécie *in concreto* et au regard de trois critères : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant (est-ce qu'il a fait traîner les choses) et le comportement des autorités nationales (est-ce qu'elles ont été diligentes).

La **cause** principale de lenteurs de la justice est avant tout le manque d'investissement budgétaire dans le service public de la justice.

- Mais de façon subsidiaire, on peut relever que le rendement des juges judiciaires a diminué : ils traitent moins d'affaires et moins vite, indépendamment des ressources budgétaires.
- Et de façon encore plus subsidiaire, il y a parfois des accidents (dossier perdu pendant plusieurs années et retrouvé tardivement…).
- Enfin, il y a de plus en plus d'affaires à juger, de plus en plus d'individus saisissant la justice pour résoudre leurs litiges.
- Mais il ne faut pas non plus oublier que la justice doit pouvoir prendre son temps, au risque d'être, non plus rapide, mais expéditive. Toute la difficulté est donc de trouver le temps « juste ».

Les **remèdes** aux lenteurs de la justice :

- Encourager le règlement amiable de leurs litiges, de façon à ce que moins de procès soient portés devant les juridictions (cela tend même à devenir obligatoire pour les « petits litiges »).
- Déjuridictionnaliser certains litiges (par ex. divorce mutuellement consenti par acte d'avocat).
- Multiplier les jugements à juge unique plutôt qu'en formation collégiale, ce qui permet d'avoir 3 fois plus de juges disponibles.
- Compliquer l'accès aux voies de recours (et de façon générique accroître les obligations procédurales des parties ; c'est la politique en matière d'appel devant les juridictions civiles depuis plus de 20 ans).
- Recruter davantage de personnel judiciaire, ce qui semble être l'orientation adoptée depuis quelques années.
- Dématérialiser les procédures, parce que les plaidoiries orales prennent du temps.
- Créer des procédures de l'urgence (ce qui revient pour l'essentiel à multiplier les référés).
- Allouer des indemnités pour dédommagement en cas de retard. En 2020, l'Etat a dû verser 2 millions d'euros au total à des plaideurs dont l'affaire avait mis trop de temps à être jugée par les juridictions judiciaires…ce chiffre est en baisse par rapport à 2019, mais il est en écrasante majorité dû à des délais déraisonnables de jugement par les Conseils de Prud'homme. On notera que cette réparation peut être accordée par la CEDH, mais aussi par les juridictions françaises elles-mêmes, dans le cadre de l'action en réparation des dysfonctionnements de la justice (cf. ci-après). En tous les cas, il est à noter que **la sanction d'un délai déraisonnable de jugement ne peut être que la réparation du préjudice qui en est résulté, jamais la nullité de la procédure ou du jugement rendu**.

# PARTIE III - LA RESPONSABILITE DE L'ETAT DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

Si le principe d'une responsabilité de l'Etat lorsqu'il échoue à rendre la justice de façon efficace est acquis dans les deux ordres juridictionnels, les règles sont différentes selon que le dysfonctionnement s'est produit dans le cadre de la justice judiciaire (TITRE I) ou administrative (TITRE II).

## TITRE I – LE DYSFONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE JUDICIAIRE

La responsabilité de l'Etat **envers les usagers du service public de la justice judiciaire** repose sur un dysfonctionnement ait eu lieu à l'occasion d'une procédure impliquant celui qui agit ensuite en responsabilité et que l'exercice d'une voie de recours n'ait pas permis la réparation du préjudice en résultant.

- Si la victime est un tiers et non un usager, la responsabilité de l'Etat repose sur un régime différent, qui n'exige de prouver aucune faute (par ex., un passant blessé par balle lors d'une opération de police).

Il peut y avoir responsabilité indépendamment de toute faute d'un juge, dès lors que l'Etat peut se voir imputer une faute lourde ou un déni de justice :

- La **faute lourde** consiste d'abord en une **erreur grossière d'un agent du service public de la justice, incompatible avec l'exercice soucieux de ses devoirs** (peu importe qui : parquet, greffe, juge, officier de police agissant sur ordre d'un magistrat) : par ex., perte d'un dossier, fuite d'un document couvert par le secret, voire acte de malveillance à l'égard d'une partie.
- La **faute lourde** consiste ensuite en une **accumulation de défaillances anormales ayant rendu le service public de la justice inapte à remplir la mission dont il est investi** (par ex., au pénal : des négligences dans l'audition des témoins, dans la médiatisation de certains éléments du dossier, dans la protection

des personnes suspectées, et qui conduit à ce qu'une victime tue l'un des suspects ; ou encore, des erreurs et des négligences dans le signalement de violences contre un enfant, qui ont conduit à la remise en liberté du suspect sans surveillance, lequel a ensuite poursuivi les maltraitances et causé la mort de l'enfant).

- Le **déni de justice** résulte en premier lieu de la **durée excessive d'une procédure** (négligence de traitement d'un dossier en état de l'être ; de façon générale, on sanctionne la paresse du juge).
- Le **déni de justice** résulte plus rarement du fait **qu'aucune juridiction ne s'estime compétente pour connaître d'un litige.** Mais il existe de nombreux recours possibles face à cette situation de sorte qu'il est rare qu'elle persiste suffisamment longtemps pour entraîner un déni de justice.

Il peut y avoir responsabilité <u>en raison de la faute d'un juge</u> :

- Mais la Cour de cassation refuse de façon constante de considérer que l'erreur d'appréciation des faits ou d'application du droit est une faute engageant la responsabilité de l'Etat (les voies de recours offrent une réparation suffisante d'une telle erreur).
- La faute personnelle d'un juge (par ex. une violation de ses obligations statutaires) peut engager la responsabilité de celui-ci, mais attention : le justiciable ne peut agir que contre l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice, pas contre le juge lui-même ; c'est l'Etat qui peut ensuite se retourner contre son magistrat (on parle d'action récursoire), mais en pratique il ne le fait jamais (il se contente de le faire sanctionner par les autorités compétentes, mais il n'agit jamais en remboursement de l'indemnité versée au justiciable).

Enfin, il existe des <u>régimes spéciaux d'indemnisation</u> :

- En matière pénale, par ex. lorsqu'on a été indûment placé en détention provisoire, ou que l'on a fait l'objet d'une erreur judiciaire ayant donné lieu à révision du procès.
- En matière civile, lorsqu'il y a une erreur commise dans la tutelle d'un majeur protégé ou d'un mineur.

## TITRE II – LE DYSFONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

L'article L. 141-1 COJ n'étant pas applicable, c'est la jurisprudence qui a dû fixer le régime de responsabilité de la puissance publique, en l'appuyant sur « les principes généraux » la régissant. On retiendra que :

- En cas de dépassement du délai raisonnable de jugement, la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute simple *(CE, ass., 28 juin 2002, Magiera)*.
- En cas d'erreur judiciaire passée en force de chose jugée, la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée *(CE, ass., 29 décembre 1978, Darmont : « Considérant que si, en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité, l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité, dans le cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive ; qu'en l'espèce, les décisions de sanction incriminées par le sieur X... et qui ont été prononcées en 1960 et 1964 sont des décisions juridictionnelles définitives ; que dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées. »).*
- Dans tous les autres cas, l'Etat peut engager sa responsabilité, mais uniquement en cas de faute lourde *(arrêt Darmont précité)*.

Il peut y avoir responsabilité pour dysfonctionnement de la justice administrative sans activité juridictionnelle au sens strict :

- Le régime de la responsabilité de l'Etat pour faute lourde s'applique en effet également aux décisions d'administration judiciaire prises en matière d'aide juridictionnelle, qui ne relèvent pas à proprement parler d'une décision juridictionnelle, mais participent du fonctionnement du service public de la justice (CE, n° 489396, 7 mai 2025, mentionnée aux tables du recueil Lebon).